

juez, la nominación de árbitro puede ser pluralista, por cuanto a voluntad del magistrado se pueden designar varios para un mismo caso. También en este caso se trata de simples particulares.

Destaco que los árbitros comienzan a tener una mayor relevancia cuando el pretor, apartándose del derecho estricto (*ius civile*), crea las llamadas "acciones arbitrarias" y las de "buena fe". En este tipo de acciones, el árbitro tiene amplia libertad, fundándose en la equidad para dictar el fallo<sup>(24)</sup>.

Debo también señalar que para la designación de jueces y árbitros se deben tener en cuenta las siguientes condiciones, a saber: edad mínima de 25 años; pertenecer a la clase "senatorial", luego extendida a los "caballeros" (*lex Sempronia*), y finalmente a los ciudadanos comunes como los comerciantes. La designación es "una carga pública", porque no puede ser rechazada por el elegido, salvo que fundamente debidamente la causal de excusación<sup>(25)</sup>. Durante la República la lista de los jueces confeccionada por los censores (*lectus senatus*) alcanza al número de trescientos ciudadanos y luego aumenta a varios miles durante el Imperio<sup>(26)</sup>.

El tribunal de los recuperadores es un colegio judicial compuesto por lo general de tres a cinco miembros, designados también entre particulares romanos. Entiende en aquellos litigios suscitados entre los peregrinos (extranjeros) y para determinados casos presentados entre ciudadanos y peregrinos. Su nombre se debe a que permiten recuperar con su intervención las cosas reclamadas por el demandante. No se trata de un tribunal permanente, sino que es designado para cada caso en particular. Debo añadir que si bien el origen histórico del tribunal es un tanto oscuro, sin embargo, la tan mentada practicidad romana le amplía con el transcurso del tiempo las más variadas funciones. Así, no sólo entiende en la simple resolución respecto de la recuperación de una cosa entre dos ciudadanos, sino también cuestiones entre romanos y peregrinos, peregrinos entre sí, o la compleja solución de un problema internacional suscitado entre dos naciones o entre sus habitantes, etc.<sup>(27)</sup>.

El tribunal de los decenviros y de los centunviros son, en cambio, colegios judiciales permanentes. Es decir que no son designados para un caso puntual, sino que se trata de tribunales que sesionan en forma permanente, una vez designados.

El tribunal de los decenviros cuenta con diez miembros y es presidido por uno de éstos. Entiende en las causas que versan sobre las cuestiones de estado y libertad (esclavitud) de los ciudadanos. La sentencia es tomada por mayoría de los miembros ante el requerimiento del presidente<sup>(28)</sup>.

Por su parte, el tribunal de los centunviros se origina aproximadamente en el año 512 a.C. Su denominación no condice con la cantidad de miembros que lo integran, por cuanto nace con el nombramiento de tres miembros por cada tribu que, sobre un total de treinta y cinco existentes en dicho momento, arroja la suma de ciento cinco miembros iniciales. Posteriormente, Augusto eleva sus miembros a ciento ochenta. Los vestigios históricos analizados permiten aseverar que si bien tienen un origen un tanto oscuro, como el tribunal de los decenviros, se constata su existencia durante toda la época clásica y hasta fines del siglo IV de la era cristiana. Actúan divididos en cuatro "colegios" (*hastae*) que se distinguen utilizando el símbolo de la antigua lanza romana (*hasta*). Cada colegio actúa como tribunal independiente, abocado a la cuestión sometida a consideración. Pero lo que llama la atención es que para ciertas causas se reúnen en "sesiones plenarias" (lo que denota una cierta similitud con los actuales "fallos plenarios").

La competencia del tribunal de los centunviros es primordialmente en materia hereditaria. Su intenso obrar al respecto origina toda la temática de "inoficiosidad de los testamentos", introduciendo la "legítima"<sup>(29)</sup>. También entiende en cuestiones de reivindicación de propiedad. En un principio tienen como lugar de reunión el foro (*forum*), luego en los pórticos de las basílicas, y después en recintos o salas especialmente habilitadas para ello que se denominan auditorías, secretarías y tabularías<sup>(30)</sup>.

Ahora bien, una vez determinado por el pretor qué tipo de juez habrá de decidir la cuestión en la segunda instancia, y elegido éste, el proceso continúa del modo siguiente. Las partes se emplazan mutuamente a comparecer ante el juez en un día determinado dentro de los tres primeros sucesivos a su designación (*denuntiatio*). La audiencia debe iniciar y finalizar el día fijado, sustanciarse mientras dure la luz diurna, y no pudiendo extenderse más allá de la puesta del sol, puede decidirse su continuación otro día si el tiempo no alcanza para dirimir la cuestión. Además, la audiencia puede postergarse por los siguientes motivos, a saber: que el juez o una de las partes deba ausentarse justificadamente (v.gr., una enfermedad, o que tuviesen el mismo día otro juicio entablado<sup>(31)</sup>).

Por fin, una vez constituido el proceso en el día fijado con la presencia del juez y las partes, con la asistencia de sus asesores jurídicos (abogados, procuradores, etc.), los litigantes deben efectuar delante del primero un breve relato dentro de los parámetros en que quedara trabada la litis. A continuación se sustancia la prueba ofrecida, que en esta época es esencialmente la testimonial, y

finalmente se procede a alegar (causa peroratio). Luego, el juez debe dictar sentencia referida a los hechos y al derecho controvertido invocados por los litigantes. El plazo para el dictado del veredicto es de 18 meses, a contar desde el inicio del proceso (lex Iulia iudiciaria)<sup>(32)</sup>.

Finalmente, me he de referir al supuesto en que una de las partes no comparezca justificadamente el día fijado ante el juez. En este caso se lo aguarda hasta el mediodía; después el juez debe dictar sentencia en favor de la parte presente<sup>(33)</sup>.

### III. LAS ACCIONES DE LA LEY EN PARTICULAR

#### 1. Acción de la ley por apuesta sacramental (legis actio per sacramentum)

Es la más antigua de las tres acciones declarativas. Consiste en una apuesta de carácter religioso que realizan las partes en conflicto y que pierde quien resulte vencido. La apuesta se formula mediante animales de rebaño y después en dinero<sup>(34)</sup>. Esta acción tiene carácter general, por cuanto se utiliza toda vez que la ley no establece un procedimiento especial para la resolución del conflicto<sup>(35)</sup>.

Mi opinión al respecto es que, si bien coincide en cuanto a que esta acción tiene carácter de aplicación general, es más apropiado señalar también que ésta, empleando una terminología más actual, tiene carácter "supletorio" o "subsidiario". Esto es así por cuanto se aplica, o se acude a ella, toda vez que por la índole de la cuestión en debate no se puede articular alguna de las restantes acciones, o sea, que ante lo que podríamos llamar la presencia de "una laguna procesal", el sistema la restaña mediante la aplicación de "la acción por apuesta sacramental". De aquí, es mi parecer, que si bien tiene en principio "carácter general", luego, ante el nacimiento de las restantes acciones, pasa a ser también de "utilización supletoria o subsidiaria"<sup>(36)</sup>.

Durante los primeros tiempos, la apuesta se lleva a cabo sólo mediante un juramento religioso; luego éste es reemplazado por una "apuesta concreta", que es depositada en "un lugar sagrado" (in sacro). El que pierde el juicio pierde también la apuesta. Esto último conlleva la siguiente evolución: primero, la apuesta se pierde en favor del patrimonio sagrado; luego, en favor de la ciudad y, finalmente, del vencedor. Posteriormente, la apuesta deja de ser concreta y pasa a ser "una promesa", pero garantizada en su cumplimiento por "fiadores" (praedes). La "acción por apuesta sacramental" puede ser real (in rem) o personal (in personam).

La "acción por apuesta sacramental sobre la cosa" (legis actio per sacramentum in rem) se implementa para la defensa de derechos absolutos de un jefe de familias sobre cosas y personas sometidas a su potestad; así, reivindicación de cosas muebles o inmuebles, reconocimiento sobre un derecho de servidumbre, reclamación de una herencia, defensa de la patria potestad sobre los hijos, la mujer y demás personas que se encuentran sujetas al poder del pater familiae, la reivindicación de esclavos, etc<sup>(37)</sup>. El procedimiento al respecto consiste en simular las partes una contienda ante el pretor, quien de inmediato ordena cesar la disputa y formularse la apuesta, que es de quinientos ases, si el valor del litigio supera los mil ases, y de cincuenta ases, si es menor a esta última cantidad o se trate sobre la libertad de un hombre<sup>(38)</sup>.

La "acción por apuesta sacramental sobre las personas" (legis actio per sacramentum in personam) tiene aplicación para hacer valer los derechos creditorios. Lamentablemente, por encontrarse ilegible el texto de Gayo a su respecto, no se tiene una mayor precisión, pero se cree que se implementa de un modo similar a la anterior, mediante la clásica apuesta<sup>(39)</sup>.

#### 2. Acción de la ley por petición de juez o árbitro (legis actio per iudicis arbitrare postulationem)

Esta acción se utiliza para los juicios de partición de herencia<sup>(40)</sup>, división de condominio (lex Licinia) y reclamo de un crédito derivado del contrato verbal "estipulación" (stipulatio). Las partes no

formulan apuesta alguna; simplemente al reclamo del demandante se opone la negativa del demandado y a continuación el pretor designaba el juez o arbitro<sup>(41)</sup>. Como se señalara, esta acción también es "declarativa".

### 3. Acción de la ley por emplazamiento o denuncia (legis actio per conductionem)

Es impuesta por las leyes Sila y Calpurnia. Por la primera se puede reclamar sumas determinadas de dinero, y por la segunda toda otra cosa concreta<sup>(42)</sup>. Se la conoce como condictio, porque proviene de condicere, que significa "denunciar"<sup>(43)</sup>. Si bien es una acción "declarativa", se diferencia de las otras acciones similares por cuanto el reclamante sólo se limita a exigir el crédito, sin estar obligado a expresar la causa de éste. Y ante la negativa del demandado, el actor lo emplaza para que en el plazo de treinta días elija juez<sup>(44)</sup>.

### 4. Acción de la ley por aprehensión corporal (legis actio per manus iniectioem)

Es el procedimiento de ejecución por excelencia, el más antiguo e importante. Nace como resabio de la atávica "venganza privada", reflejada en la vetusta forma de contratación romana del nexum, por la cual el deudor garantiza la obligación asumida con su propio cuerpo. Justamente para evitar los abusos a este respecto, se decide que el apoderamiento corporal del deudor tiene que llevarse a cabo mediante la intervención judicial, y no directamente por decisión del acreedor. De este modo, la autoridad debe constatar previamente la existencia del derecho, para luego autorizar la ejecución.

En mi opinión, se trata de un claro ejemplo de "garantía jurídica en favor del más débil" (el deudor), con el propósito de que no fuera conculcado por quien le exige el pago de la deuda. Me he referido a este tema al hablar de "la parte dogmática del orden constitucional romano", dado que, a mi entender, uno de los pilares de la grandeza del derecho romano gira en pos de "la defensa del más débil". De este modo surge la "acción por aprehensión corporal".

La acción tiene aplicación en los siguientes dos supuestos: a) cuando se reclaman ante el magistrado deudas de dinero que el demandado reconoce expresamente mediante confesión (confessus); b) cuando el deudor niega la deuda y es condenado judicialmente mediante sentencia dictada por el juez a pagarla (iudicatus)<sup>(45)</sup>.

La acción de "aprehensión corporal" (manus iniectio) se implementa transcurridos los treinta días de dictada la sentencia en favor del acreedor ante cualquiera de los dos supuestos mencionados<sup>(46)</sup>. Vencido este plazo, y no habiendo sido saldada la deuda, el deudor es llevado por la fuerza por el acreedor nuevamente ante el magistrado, pronunciando las palabras solemnes exigidas por ley, invocando la sentencia por la cual el deudor ha sido condenado. El inicio de la ejecución no puede ser detenido sino por el pago inmediato de la deuda o el nombramiento de un fiador (vindex)<sup>(47)</sup>, que se subroga respecto de la obligación del deudor<sup>(48)</sup>. En este último supuesto se lleva a cabo un nuevo juicio contra el vindex, en el cual el juez debe expedirse sobre la legitimidad de la solicitud de la "ejecución corporal" iniciada contra el deudor. Para el caso de que se compruebe la procedencia legal del inicio de la acción, el vindex debe pagar el doble del importe de la deuda originaria o, por el contrario, el acreedor tiene la vía expedita para ejercer la "aprehensión corporal" sin que pueda ya ofrecerse nuevo vindex.

Ahora bien, para el caso de que el deudor no suministre vindex, o que en definitiva la deuda no sea saldada, el deudor es declarado addictus y el acreedor queda legalmente facultado para llevarlo a su casa y encadenarlo como si fuera un esclavo. El peso de las cadenas no debe superar las quince libras y el propio deudor debe preocuparse de su alimentación, pero para el caso de que no lo puede hacer, el acreedor está obligado alimentarlo hasta el equivalente a una libra de harina diaria o más, si es su voluntad<sup>(49)</sup>. Durante el tiempo en que el deudor permanece en poder del acreedor se puede acordar el cumplimiento de la deuda. Si ello no acontece, el deudor es llevado atado por el acreedor durante tres días a distintos mercados para que algún conocido se apiade de

su situación y pague la deuda, obteniendo su libertad<sup>(50)</sup>. De no ocurrir esto último, y pasados los tres días citados, el acreedor puede vender al deudor como esclavo del otro lado del río Tíber (trans Tiberim).

En verdad, lo dicho no causa problemas de interpretación cuando se trata de un solo acreedor, pero ante la circunstancia de que éstos fuesen varios, la ley de las XII Tablas es elocuente al respecto al señalar duramente que al deudor "le partan en pedazos", en clara referencia a la pluralidad de los acreedores. A este respecto, la doctrina romanista es conteste en afirmar que no se conocen casos de dicha aplicación rigurosa<sup>(51)</sup>. Fundamentalmente se tiene en cuenta al respecto lo vertido por las fuentes. Así, Aulo Gelio señala: "No he leído ni oído decir que ningún hombre fuese despedazado en la Antigüedad; ¿por qué? Porque no se arrostra semejante castigo"<sup>(52)</sup>.

Sumo mi opinión en cuanto a que, de haberse aplicado semejante pena, el caso necesariamente habría de ser recogido por alguna de las fuentes (v.gr., jurídica, histórica, literaria, etc.). El propio Aulo Gelio lo afirma cuando dice: "No he leído ni oído decir". Por el contrario, de ser una punición habitual, no es necesario que dicho autor se expida al respecto. Es más, niega la ocurrencia de tamaño castigo que, según sus propios dichos, parece hasta repugnante al "sentir romano". Además de lo expuesto, añado que, en el fondo, lo que la "ley decenviral" quiere significar es dejar en claro que el acreedor que en esa época, por lo esencial, es un "jefe de familias", tiene todo el poder que le da su autoridad para ejercer plena ejecución contra el acreedor según su voluntad y sin impedimentos. Incluso para el caso de pluralidad de acreedores, ese poder absoluto puede ser ejercido por todos a la par, dividiéndose el cuerpo del deudor por el número de acreedores. Ése es el verdadero sentido de la ley, ratifica el poder pleno y absoluto de los "padres de familias", pero en definitiva, y como bien lo sostiene Aulo Gelio, "nunca se aplicó", porque es contrario al "sentir de un romano". Por dicha razón no se conocen casos a este respecto, dado que tener semejante poder, reconocido incluso por ley, hace que deba ser aplicado con mesura. Por eso el comentario del propio autor romano cuando señala: "No se arrostra semejante castigo". En definitiva, se procedía a la venta del deudor y el precio pagado se dividía entre los acreedores.

# FRANJA MORADA

## 5. Acción de la ley por toma de prenda (legis actio per pignoris capionem)

Es el apoderamiento extrajudicial por parte del acreedor impago de una cosa mueble del deudor (pignus) para garantizar el cumplimiento de lo adeudado. Es considerada una acción de ejecución, aunque de carácter excepcional y no general, como la anterior. Esta acción tiene una gran similitud con la medida actual de embargo. Se ha discutido si por propia naturaleza es en verdad una acción, por cuanto se puede llevar a cabo fuera del asiento del tribunal del magistrado, incluso en ausencia del deudor y aun en días nefastos. Pero las fuentes son claras al respecto, al sostener que debe considerarse como otra de "las acciones de la ley" (legis actiones), en virtud de la utilización de determinadas palabras que la autentican como tal<sup>(53)</sup>.

Esta acción puede ser empleada en los siguientes casos: el vendedor contra el comprador que no ha pagado el precio cuando el objeto de la venta es un animal destinado a ser sacrificado a los dioses (hostia); contra quien no pague el alquiler de un animal de carga cuando el importe se destina a un sacrificio religioso; a los publicanos contra los deudores del arrendamiento de la vectigalia (ager vectigali); el soldado contra el tribuno encargado del pago de los sueldos (tribunus aerarii) por los estipendios adeudados (aes militare); el soldado de caballería (eques) por la suma asignada para comprar el caballo (aes equestre) contra los deudores que son viudos y casados sin hijos (viduae et orbi), siempre que posean cierto patrimonio; el soldado de caballería por la suma destinada a forraje (aes hordiarum)<sup>(54)</sup>.

## IV. EL SISTEMA DEL PROCESO FORMULARIO

Según refiere el propio Gayo, las acciones de la ley "se volvieron paulatinamente odiosas, porque, por la exagerada precisión de los antiguos que crearon esos derechos, se llegó a tal punto que el menor error implicaba la pérdida del litigio"<sup>(55)</sup>.

Esto es así, por cuanto el sistema de "las acciones de la ley", que tan bien contribuye a dirimir los primitivos conflictos en forma civilizada y pacífica, colapsa ante la expansión social y económica de Roma. El mero hecho de que el sistema es de aplicación exclusiva para los ciudadanos romanos, excluyendo a los peregrinos, es índice de insuficiencia. La creación de la pretura peregrina coadyuva al cambio. Por demás, el carácter riguroso, severo y estricto de "las acciones de la ley", que hace perder el derecho al actor que comete un simple error tan sólo en la exposición de los hechos o el derecho y que entorpece la defensa del demandado por cuanto no puede articular todas las defensas a su alcance debido a que para ello tiene que, a su vez, iniciar un nuevo juicio contra quien le demanda, unido a la falta de la representación en juicio que obliga a los litigantes estar presentes bajo pena de perder el derecho, lentamente torna al sistema en ineficaz e impopular.

En mi opinión, el otro grave problema que evidencia el viejo sistema, y que lo convierte también en inseguro, es la oralidad del procedimiento. Los hechos y el derecho invocados por el demandante y la defensa articulada por el demandado son verbales, y la principal prueba es la testimonial, lo cual, aunado al incremento de la complejidad de los temas en debate, hace perder confianza al sistema de "las acciones de la ley", originando uno nuevo, el "proceso formulario", que emerge paulatinamente sin reemplazar al primero, coexistiendo ambos un tiempo, hasta que el nuevo se impone por completo.

Previamente a implementar el nuevo sistema procesal existen otros intentos de reformas, como el impuesto por la lex Papiria (288 a.C.) y el denominado per sponsionem<sup>(56)</sup>, que si bien logran agilizar, de cierto modo, el sistema de las "acciones de la ley", no alcanzan para constituirse en solución definitiva. Por esto, el "procedimiento formulario" se origina con la sanción de la lex Aebutia (130 a.C.), que dispone expresamente que los pleitos entre ciudadanos pueden plantearse y resolverse mediante "una instrucción escrita" que el pretor debe elevar al juez (iudex) y que toma el nombre de "fórmula", sin necesidad de acudir a las "acciones de la ley". Más tarde, en tiempo de Augusto (23 a.C.), el nuevo sistema es complementado por una ley que ordena que las designaciones de juez en la instancia "de derecho" deben hacerse por medio de "fórmulas", y no mediante los requerimientos de las "acciones de la ley" (lex Iulia iudiciorum privatorum)<sup>(57)</sup>.

Sin perjuicio de lo expuesto, como lo señalara más arriba, el nuevo sistema no reemplaza de inmediato al anterior, sino que ambos coexisten un tiempo, junto a las demás reformas indicadas, hasta que finalmente predomina por completo el "procedimiento formulario"<sup>(58)</sup>.

El nuevo sistema mantiene las mismas características generales del sistema anterior en cuanto a la división del proceso en las dos etapas estudiadas: la primera, "de derecho" (pretor), y la segunda, "en juicio" (juez, árbitro o tribunal). La primera etapa se inicia con la comparecencia de las partes ante el magistrado, con quien, luego del correspondiente trámite, a redactan la "fórmula" que debe ser remitida al juez que entiende en la segunda instancia ("en juicio"). Justamente de este modo se quiere evitar la inseguridad que trae consigo el sistema anterior mediante la oralidad del acto en la remisión de la pretensión del actor y la defensa del accionado.

## **V. LA ETAPA "DE DERECHO" (IN IURE) EN EL PROCESO FORMULARIO IMPORTANCIA DEL PRETOR**

Esta instancia mantiene el mismo esquema procesal que el sistema de las "acciones de la ley", es decir, el comienzo y el fin mediante los actos procesales de la in ius vocatio y la litis contestatio.

La "citación privada del demandado" por parte del reclamante (in ius vocatio) es similar a lo expuesto en el sistema de "las acciones de la ley", sólo que es perfeccionada y completada. En este sentido, el actor debe hacer saber al accionado qué "fórmula" ha escogido de las que lucen en las tablas expuestas en el foro (albo pretorio). La manera de darle a conocer la "fórmula" elegida al demandado varía según la época; así, basta simplemente que el actor se la señale con el dedo ante su presencia o entregarla por escrito al interesado. Luego esto último se hace común, con el agregado del objeto y día fijado para la comparecencia.



El nuevo sistema se complementa con nuevas "acciones especiales" concedidas por el pretor para asegurar la comparecencia del demandado ante su presencia; v.gr., contra el "garante" (vindex) que no cumple con la obligación de la concurrencia del demandado (actio in factum); contra el demandado que, una vez citado, no comparece o no ofrece "garante", o contra terceros que interfieren adrede a la comparecencia del demandado (actio in factio penalis)<sup>(59)</sup>. También se permite que el demandado se torne en su propio garante mediante juramento y bajo pena de pagar una multa si no comparece (vandimonium)<sup>(60)</sup>; y lentamente, incluso, se comienza a autorizar la representación judicial por terceros (mandato).

Efectuada la "citación privada del demandado", éste puede o bien comparecer o no hacerlo. En el primer caso, comienza el proceso en sí mismo. En el segundo supuesto, si se trata de una "acción real", la cosa en disputa se considera de propiedad del reclamante ante la ausencia del demandado, y si es una "acción personal", se castiga la incomparecencia del deudor ordenando la entrega de los bienes del deudor para su venta pública<sup>(61)</sup>.

Ahora bien, comparecidas las partes ante el magistrado, el reclamante expone ante este último cuál es su pretensión (edictio actionis), solicitando que haga lugar a la acción cuando está contemplada por "el edicto" (actiones vulgares), o que le otorgue protección jurídica si es una situación aún no prevista en éste (postulatio actiones).

En el primer supuesto, el proceso se simplifica, por cuanto el reclamante sólo debe presentar un bosquejo de la "fórmula", según el modelo escogido en "el edicto" (albo pretorio), y dado a conocer al demandado en la "citación privada".

El segundo caso, en definitiva, a mi entender, es el más importante por "la creatividad jurídica del pretor". Éste debe analizar la situación especial planteada por el demandante y, si la considera razonable, le otorga viabilidad jurídica, creando una nueva "fórmula" (in factum actione), o adaptando una existente al caso (utilis actione) en virtud del imperium que ostenta<sup>(62)</sup>.

He aquí lo dicho en oportunidad de referirme a las facultades y atribuciones del pretor, esencialmente el peregrino, cuando señalé, sin dudas, que es el magistrado más importante desde el punto de vista del derecho, por cuanto con su actividad creadora y sin pausa "crea derecho" a través de nuevas "fórmulas" que otorga mediante "acciones". Esto no significa que el demandante tenga "razón", sino que "lo legitima" para "estar en juicio". Luego corresponde al interesado demostrar que "le asiste la razón", produciendo la prueba respectiva ante el juez, árbitro o tribunal, según fuere el caso. Lo importante es "la creación" de la "nueva fórmula", ya sea en original o mediante adaptación de una anterior, que permite, una vez incorporada al "edicto" (albo pretorio), ser invocada por todo litigante en el futuro ante un caso similar. Destaco también que la actividad del pretor se completa "otorgando" (datio) o "denegando" (denegatio) la acción invocada existente, e incluso su solicitud de "creación"<sup>(63)</sup>.

Antes de la redacción de la "fórmula", el magistrado puede tomar ciertas medidas que de un modo u otro influyan en la prosecución del proceso, que son las siguientes: "interrogación", "confesión" y "cauciones".

La "interrogación" (interrogatio in iure) es una medida admitida para que el accionante pueda recabar datos necesarios para precisar los hechos y el derecho de su petición, evitando posibles errores sobre ellos. Consiste en un interrogatorio preventivo efectuado al demandado, que está obligado a responder, siempre que el pretor considere que las preguntas formuladas por el reclamante son procedentes. La medida tiene importancia, también, porque las respuestas del demandado son tomadas como prueba anticipada de la litis. Se utiliza especialmente en los procesos de petición de herencia y en las acciones noxales<sup>(64)</sup>.

La "confesión" (confessio in iure) es el reconocimiento efectuado por el demandado del derecho invocado por el actor. En este caso, el juicio finalizaba en la "etapa de derecho", no pasando a la siguiente, con carácter de cosa juzgada y, además, el demandado tiene que cumplir lo adeudado mediante el pago de una suma de dinero (lex Aebutia)<sup>(65)</sup>.

Las "cauciones" (cautiones) se originan ante la admisión de la representación judicial por parte de terceros, por cuanto éstos, en definitiva, son los destinatarios de la sentencia al ocupar el lugar del demandado. Justamente para evitar el nombramiento de terceros insolventes, burlando el derecho del accionante, se hace lugar otorgar "cauciones" para garantizar el cumplimiento de la pretensión para el caso de que venza en el pleito. Las "cauciones" pueden presentar varias modalidades, así, entre otras, la que brinda el demandado asumiendo la responsabilidad del resultado del juicio, la que otorga el representante al actor garantizando el cumplimiento por parte del representado, etc<sup>(66)</sup>. El incumplimiento con la caución aparea la pérdida de aquello estipulado

como garantía; y si el demandado se niega a otorgarla, es conminado por el magistrado a hacerlo bajo apercibimiento de severas penas<sup>(67)</sup>.

Finalizadas las diligencias procesales previas, siendo concedida la acción por el pretor al demandante, el proceso se encuentra en condiciones de la redacción de la "fórmula".

## VI. LA FÓRMULA. SUS PARTES

En principio, se redacta un "proyecto de fórmula" por el magistrado en el caso de una pretensión no contemplada en "el edicto", o por el propio demandante, cuando su reclamo está incorporado en éste último. El "proyecto" se traslada al demandado, que lo puede rechazar o aceptar en forma total o parcial, e incluso interponer una excepción que a su vez el demandante debe contestar, correspondiendo al pretor decidir si ha de figurar o no en la redacción final de la "fórmula". Aprobada esta última de manera definitiva, el pretor emite un edicto por el cual designa juez, a la vez que determina los elementos sobre los que éste debe fundar el veredicto, otorgándole atribución para condenar o absolver al demandado.

Entiendo que el acto edital debe ser considerado como un tipo de "delegación" puntual del imperio del pretor para el dictado de dicha sentencia, en particular legalizándola.

La "fórmula" consta de diversas partes, que pueden ser agrupadas en esenciales y accidentales. Las primeras son las que necesariamente deben constar en la redacción (desmonstratio, intentio, adiudicatio y condemnatio). Las segundas son aquellas que pueden o no figurar a petición de la parte interesada, y siempre que tengan injerencia en la resolución del juez (exceptiones y praescriptiones)<sup>(68)</sup>.

Las partes esenciales en particular son las siguientes: 1) La demonstratio es la que encabeza la "fórmula" por la cual se da a conocer el asunto sobre el que se litiga. Es una exposición abreviada de los hechos, el derecho y la causa de la acción<sup>(69)</sup>. 2) Laintentio es lo medular de la "fórmula", por cuanto fija la petición del demandante. Por lo general puede tener varias modalidades en su redacción<sup>(70)</sup>, pero siempre consiste en el objeto del litigio sobre el cual el juez debe emitir sentencia<sup>(70)</sup>. 3) La adiudicatio es donde se consigna al juez la facultad de adjudicar algo litigioso a alguna de las partes<sup>(71)</sup>. 4) La condemnatio es la concesión al juez de la atribución de condenar o absolver<sup>(72)</sup>.

En mi opinión, es fundamentalmente en las dos últimas partes de la "fórmula" donde se advierte claramente la "delegación" de funciones por parte del pretor a que he hecho referencia ut supra.

Las partes accidentales en particular son las siguientes:

1) La exceptio, que es la defensa propiamente dicha del demandado. Consiste en la contraposición de la acción invocada por el reclamante, enervando la intentio y la condemnatio. Se origina por la actividad propiamente del pretor en la búsqueda del equilibrio que debe imperar entre las partes. El viejo sistema de las "acciones de la ley" no permite al demandado ejercer debidamente el derecho de defensa. Por tal motivo, el pretor comienza a paliarlo mediante la inclusión de la exceptio, cuanto lo considere necesario. En determinados casos, el pretor concede traslado de la excepción interpuesta por el demandado al accionante, que a su vez la contesta (replicatio), generando un nuevo traslado (duplicatio), y así sucesivamente (triplicatio, etc.), y, según el parecer de las fuentes, sin término fijo para ello<sup>(73)</sup>.

Por eso, entiendo también, el carácter excepcional de la exceptio, por cuanto es el pretor quien debe analizar y decidir finalmente su inclusión y posterior traslado para no generar una prolongación sin causa del proceso en el tiempo. Además, he aquí la demostración de la función de organizador y director del pretor en el procedimiento, encauzándolo debidamente.

Gayo brinda, magistralmente, una clasificación de las "excepciones" que aún es moderna y de plena aplicación en los códigos de procedimiento, demostrando el genio de los juristas romanos, que han creado instituciones de derecho que traspasan el tiempo y permiten acentuar lo que he dicho en la primera parte del presente libro respecto de que el "derecho romano es derecho vigente".

Gayo divide las "excepciones" en perentorias (exceptiones aut perem-toriae) y dilatorias (exceptiones aut dilatoriae). Las primeras son definitivas, tienen efecto extintivo, porque contraponen

de tal modo la acción que la neutralizan e impiden que pueda ser articulada nuevamente (v.gr. excepción de cosa juzgada, dolo malo, etc.). Las segundas son temporales, no tienen efecto extintivo (v.gr. el pacto de no demandar por cierto tiempo, lo cual implica que durante dicho lapso la acción queda paralizada, reanudándose a su vencimiento). Otras excepciones son las que se oponen contra ciertas irregularidades o defectos en la representación del demandante (v.gr. incapacidad del que ejerce el mandato o del otorgante). Solucionado el inconveniente, el proceso puede continuar<sup>(74)</sup>.

Debo destacar que las fuentes también formulan otras clasificaciones de las "excepciones", sobre las que, en rigor del presente, no puedo extenderme, limitándome al tratamiento de las indicadas precedentemente en razón de su utilidad práctica actual<sup>(75)</sup>.

2) La praescriptio es la parte de la "fórmula" que consiste en instrucciones otorgadas por el pretor al juez para que en la sentencia tenga en cuenta determinadas circunstancias de la litis, que, de ser soslayadas, la tornan en injusta para cualquiera de las partes. No tiene una ubicación fija en la fórmula, dado que puede encontrarse antes de la demonstratio o remplazándola directamente, o bien antes de la intentio<sup>(76)</sup>.

Una vez redactada la "fórmula" de modo definitivo y conocida por las partes la instancia "de derecho", finaliza con la "litis contestatio". Este acto procesal es de suma importancia, por cuanto éste las partes convienen en forma expresa en someterse al resultado de la sentencia según los términos de la "fórmula". Esto significa que la "litis contestatio" presenta un carácter regulador y extingue la acción interpuesta, de modo tal que no puede ser nuevamente invocada, haciendo "nacer" para las partes una nueva relación jurídica que consume a la primera, creando una nueva en reemplazo de la anterior<sup>(77)</sup>.

## VII. LA ETAPA "EN JUICIO" (APUD IUDICIUM) EN EL PROCESO FORMULARIO

Esta instancia se sustancia a continuación de la etapa "de derecho", una vez finalizada con la "litis trabada". Se tramita ante el juez o jueces según la índole de la cuestión en debate, debiendo las partes producir sus pruebas ante aquéllos, y finaliza con el dictado de la sentencia.

Por lo general, esta instancia guarda similitud con la anterior, de las "acciones de la ley", pero presenta cierta variedad de matices que he de indicar en su caso. Como dije, el pleito se sustancia ante un juez, árbitro o tribunal (recuperadores). La designación de los dos primeros es similar a la descripta en el sistema anterior, y en la del último se sortea un número de los que componen permanentemente el colegio. También continúan actuando los tribunales de los decemviriri y centumviri.

Las partes comparecen el día fijado con sus respectivos asesores legales (abogados, oradores, etc.) ante el juez o tribunal designado, que estudia cuidadosamente el contenido de la "fórmula", especialmente las instrucciones que en ella le imparte el pretor. La audiencia se debe sustanciar en el transcurso del día señalado, iniciándose al alba y finalizando con la puesta del sol. Al inicio, las partes efectúan una breve exposición de la causa para ilustrar al juez, aunque éste ya está compenetrado con el asunto por haber examinado previamente la "fórmula". A continuación, las partes y sus asesores comienzan los debates mediante alegatos y discursos (causa peroratio). Para evitar que éstos se extiendan más de lo aconsejable, se determinó una duración máxima de una hora (lex iudiciorum prevatorium). Finalizados los debates, se sustancia la prueba ofrecida por las partes en apoyo de su derecho. Los medios de prueba son más avanzados que en las "acciones de la ley"; así, pueden ser testimonial, confesional, juramento, documental, inspección ocular, peritos, etc<sup>(78)</sup>.

Es necesario en el juicio la presencia de las partes por sí mismas o mediante apoderados. En caso de que no lo hicieran, como todavía no se conoce el instituto de la rebeldía, se aplican diversas sanciones para los que no concurren. Si el ausente es el actor, el demandado es absuelto. En cambio, si el que falta es este último, en un principio, se le da por perdido el juicio, mas luego se introduce la idea de que se lo debe condenar sólo si el juez tiene la convicción de que el reclamo es justo; si no, aunque no se presente, igualmente la acción se rechaza<sup>(79)</sup>.



## VIII. LA SENTENCIA

La decisión del juez o tribunal pone fin a la etapa "en juicio". Tiene lugar una vez rendida y analizada la prueba ofrecida. Quien juzga debe hacerlo teniendo en cuenta las instrucciones dadas por el magistrado en la "fórmula", no pudiendo apartarse de ella. La sentencia es dada a viva voz, indicando con precisión la absolución o la condena del demandado. En este último caso, la misma debe estar expresamente determinada. Para el caso de que actúe un solo juez, basta su opinión, aunque antes de emitirla puede consultar libremente a sus consejeros. Si se trata de un tribunal, la decisión se toma por simple mayoría, y las abstenciones se cuentan como votos en contra. Si media empate, se hace lugar a la absolución del demandado. Si la discrepancia es en cuanto al monto, se toma la suma menor<sup>(80)</sup>. Además, la sentencia tiene que ser fiel a la "fórmula", es decir, relacionada con las probanzas efectuadas, el derecho alegado y los hechos invocados por las partes litigantes<sup>(81)</sup>. El contenido de la condena es siempre de carácter dinerario, estimando el juez su monto (aestimatio). Una vez emitida la sentencia, la función del juzgador finaliza. La ejecución se realiza ante el magistrado, por cuanto es quien tiene imperium, atribución de la que carece, como se ha visto, el juez.

La sentencia es inapelable, por cuanto es emitida por un juez elegido por las partes, o, en su defecto, por el pretor. Como esto conduce en algunos casos a verdaderas inequidades, por cuanto los juzgadores se equivocan o fallan de modo contrario a derecho, aun siguiendo fielmente las instrucciones de la "fórmula", se remedia el carácter inapelable de la sentencia del juez privado mediante la concesión de medidas que llevan a su anulabilidad (intercessio, revocatio in duplum, in integrum restitutio, etc.)<sup>(82)</sup>.

Una vez consentida la sentencia o rechazados los recursos intentados en su contra, se hace "cosa juzgada" (res iudicati). La ejecución de la sentencia, como se ha visto, no puede llevarse a cabo ante el juzgador que la emite, sino que el vencedor debe acudir nuevamente ante el magistrado, quien tiene autoridad (imperium) para entender en ella. Para tal fin, el ejecutante debe iniciar un nuevo juicio (actio iudicati), similar en todo al anterior, pero con la variedad de que éste tiene carácter ejecutivo, es decir que, firme la sentencia de ejecución, puede exigir el cumplimiento de la condena en la persona del vencido, pero sin llegar a la severidad de la "acción de aprehensión corporal" de las "acciones de la ley". Más tarde, se permite efectivizar la condena sobre los bienes del deudor y no sobre su persona, así, mediante su venta en bloque (bonorum venditio)<sup>(83)</sup>, o de ciertos bienes en particular (honorum distractio)<sup>(84)</sup>. Después, en forma paralela, aparecen otros tipos de medidas de ejecución, como, por ejemplo, "la cesión de todos los bienes del vencido al acreedor" (cessio bonorum), dispuesta en el año 47 a.C. (lex Iulia de bonis cedentis)<sup>(85)</sup>, y la "toma de posesión del acreedor de bienes del deudor para su venta posterior y percibir el crédito con el resultado de ésta" (pignus in causa iudicati). Este último tipo de ejecución presenta ciertas particularidades que bien vale detallar (v.gr., el apoderamiento de los bienes del deudor no lo lleva a cabo el acreedor, sino funcionarios del magistrado destinados a tales efectos por éste [apparitores] [similares a oficiales de justicia modernos]). La toma en prenda de los bienes debe llevarse a cabo preferentemente sobre bienes muebles (dinero, esclavos, etc.); a falta de éstos, sobre inmuebles y, por último, sobre los derechos de créditos que tuviera. Lo tomado en prenda queda en caución por el plazo de dos meses, con el fin de que el deudor pueda recuperarlos mediante el pago de la condena; pero una vez vencido el plazo, y no satisfecha la deuda, los mismos funcionarios, por orden del pretor, deben subastarlos públicamente al mejor postor<sup>(86)</sup>.

## IX. LAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DEL MAGISTRADO

El sistema del "procedimiento formulario", previendo en determinadas situaciones la necesidad jurídica de una "pronta resolución", porque de lo contrario se ocasiona un perjuicio justamente al que invoca protección, (v.gr., alimentos, o el resguardo de una pretensión que de incurrir en demora fenece), le permite al pretor, en virtud del imperium, entender en dichos asuntos, sin que implique la sustanciación de un juicio propiamente dicho. Son las denominadas "medidas extraordinarias del magistrado", como "las estipulaciones pretorias" (praetoriae stipulationes), "las restituciones

íntegras" (in integrum restitutiones), "los envíos en posesión" (missiones in possessionem) y "los interdictos" (interdicta).

a) Las "estipulaciones pretorias" consisten en medidas cautelares ordenadas por el pretor mediante el antiguo contrato verbal de "estipulación" (stipulatio) para asegurar una obligación jurídica existente u otra futura<sup>(87)</sup>. Son de variada índole y numerosas. A modo de ejemplo citaré las siguientes: la otorgada para garantizar la comparecencia ante el magistrado el día prefijado por el citado como demandado; la brindada por el accionado por la acción de reivindicación para garantizar la devolución de las cosas y frutos litigiosos en caso de una sentencia desfavorable, etc<sup>(88)</sup>.

b) Las "restituciones íntegras" tienen como finalidad hacer que las cosas vuelvan a su estado jurídico original por razones de equidad, declarando inválido un negocio jurídico<sup>(89)</sup>. Fundamentalmente se debe tener en cuenta que los efectos del negocio jurídico que se invalida no produzcan daños a una de las partes o incluso a terceros ajenos a la relación<sup>(90)</sup>. Tiene lugar siempre y cuando la situación permita que se pueda restituir al estado anterior. Es importante destacar que esta medida se concede en un principio a casos excepcionales, pero luego es extendida, por la actividad de los mismos pretores y de la jurisprudencia, a situaciones de la más diversa índole en que se ve afectado un derecho. A modo de ejemplo, tenemos los actos inválidos por vicios del consentimiento (v.gr., error, dolo, fraude), por estar involucrado un menor de 25 años, etc<sup>(91)</sup>.

c) Los "envíos en posesión" son medidas de garantía de carácter provisorio por las cuales el magistrado otorga la posesión más o menos duradera de los bienes de una persona a otra. Las medidas varían según el objeto que tienen en mira. Así, recaen sobre "el patrimonio íntegro de una persona" o "un bien en particular"; es el caso de la entrega del patrimonio como punición (missio in bona), o cuando un individuo lo reclamaba invocando un derecho (bonorum possessio, bonorum venditio)<sup>(92)</sup>. Es interesante determinar que estas medidas pueden ser otorgadas de dos modos diferentes: uno, institucionalizado, es decir, cuando la misma figura inserta en "el edicto"; entonces el pretor la concede con sólo solicitarla el interesado (bonorum possessio edictalis); la otra es la que no está prevista en "el edicto" y es cuando el pretor la concede en razón de equidad mediante "decreto" (bonorum possessio decretalis). En este último caso se advierte la actividad creativa del pretor, por cuanto, mediante estas "medidas de garantía o cautelares", crea verdadero derecho; así, las otorgadas, "a la mujer embarazada sobre los bienes de una herencia a la que pudiera tener derecho el que lleva en su seno" (nasciturus); "al tutor del impúber cuya filiación se encuentra discutida"; "al curador del insano sobre los bienes que su pupilo tiene derecho a heredar", etc<sup>(93)</sup>.

d) Los "interdictos" son órdenes dictadas por el pretor a solicitud de un ciudadano con el objeto de obtener el fin de una disputa. Se originan en el "derecho público", donde la autoridad del magistrado es necesaria para proteger las "cosas públicas y sagradas". Luego la aplicación de los "interdictos" se extiende al "derecho privado" para proteger "pretensiones" de los particulares que, sin constituir "derechos", necesitan ser resguardadas de ataques arbitrarios. Son situaciones controvertidas que, al no estar protegidas por una "acción" ni tampoco poseer "fundamento inmediato para que se otorgue una nueva", necesitan de igual modo ser resguardadas. Consecuente con su finalidad, en un principio, el interdicto consiste en "una prohibición", pero después se extiende a "hechos positivos" sujetos a comprobación judicial posterior<sup>(94)</sup>. Tienen por objeto "exhibición de cosas o personas" (interdictosexhibitorios), "restitución de cosas o destrucción de obras" (interdictos restitutorios), "la abstención de determinados actos" (interdictos prohibitorios), etc<sup>(95)</sup>.

Siendo "los interdictos medidas extraordinarias", no se encuentran regulados en el "procedimiento", sino que, por el contrario, están sujetos, en un principio, a la impronta de los magistrados. Como éstos coinciden, lentamente, en el modo de sustanciarlos, se va generalizando aquél hasta lograrse "un procedimiento interdictal" similar para todos los supuestos semejantes que se presentan cotidianamente. Este "procedimiento", en lo esencial, se origina con la petición de protección de una "pretensión", aun cuando fuera día nefasto, por parte de un particular, sin que sea indispensable la presencia de aquél contra quien ha de dirigirse la orden. El pretor analiza de modo sumario la petición; cita, de ser necesario, a la otra parte, y luego concede o deniega "el interdicto", según el caso<sup>(96)</sup>. Esto no significa que el beneficiado con "el interdicto" haya vencido en la contienda, si no que logra "la protección provisorio" de "la situación de derecho" que considera se daña si no se la resguarda. Después, según los casos, se verá, mediante la dilucidación judicial (jueces, árbitros o tribunales), a quién le asiste la razón. Pero la finalidad del "interdicto" se ha logrado; es decir, "el resguardo, la protección" del supuesto derecho en peligro<sup>(97)</sup>.

e) Los "interdictos prohibitorios" son las órdenes que el pretor emite para que no se consumen determinados actos que pueden ser perjudiciales para quien peticiona la protección. Son ejemplos

de éstos: la "protección del goce de cosas del dominio público"; la "protección del lugar de una sepultura"; la "protección a favor del que goza de un derecho real de superficie"; la "protección otorgada al locatario sobre los bienes que da en garantía de pago del canon ante las retenciones abusivas dispuestas por el locador"; "permiso otorgado al propietario de un edificio para cortar los árboles del vecino cuyas ramas se extienden sobre su inmueble", etc.<sup>(98)</sup>.

f) Los "interdictos restitutorios" son órdenes que disponen la restitución de una cosa a una persona, o bien que se restituya a su anterior estado cuando se hubiera modificado sin autorización del titular, con el pago de los daños e intereses a que hubiera lugar (v.gr., "al que ha sido desposeído mediante violencia o dolo de un inmueble"; "el que se niega a restituir una cosa que se le ha entregado con la obligación de devolverla al primer requerimiento", etc.<sup>(99)</sup>).

g) Los "interdictos exhibitorios" son órdenes para que se exhiban personas o cosas (v.gr., "la recuperación de una persona que se halla dolosamente privada de la libertad"; "la exhibición de personas libres"; "que una persona presente un testamento u otra disposición de última voluntad sobre la que existe certeza de que contiene disposiciones en su favor", etc.<sup>(100)</sup>).

Debo detenerme en el análisis del "interdicto exhibitorio", por cuanto encuentro en el referido "a personas", como lo señalé al referirme al aspecto dogmático del ordenamiento constitucional romano, el origen del actual "hábeas corpus"; además, en "el de cosas", encuentro la raíz de la norma procesal moderna que ordena la integración a la litis de la documental en poder de las partes o de terceros, que hacen a su dilucidación.

## **X. LAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DEL MAGISTRADO Y LA REFORMA DEL PROCEDIMIENTO**

Se debe a la intensa y calificada actividad jurídica del pretor, especialmente a sus "medidas extraordinarias", el nacimiento de un nuevo "sistema procesal" que da por finalizado el antiguo "procedimiento formulario" e inicia el moderno.

En principio debo señalar en este aspecto la gravitación de la coyuntura política, por cuanto es a partir de Diocleciano (284) y el implemento de sus reformas que nos encontramos en el umbral del sistema procesal actual. Justamente, Diocleciano, empeñado en concentrar el poder en sus manos, advierte que una función trascendental como "impartir justicia" no puede quedar en "manos de simples particulares". Por ende, el viejo sistema ("acciones de la ley" y "formulario"), donde la presencia del Estado se configura en la primera instancia ("de derecho") con la actividad del pretor, y luego en la ejecución de la sentencia dictada por "particulares", deja de tener injerencia ante la absorción de todos los atributos del poder en manos del emperador.

Esto implica la eliminación del sistema antiguo, la desaparición de las dos instancias consabidas ("de derecho" y "en juicio"), la fusión de ambas en las atribuciones otorgadas en la persona del "juez" en sentido moderno, quien toma el juicio desde el inicio (demanda, contestación), sustancia la prueba y dicta sentencia. Es el Estado, entonces, el protagonista mediante el juez, funcionario de aquél, quien lleva adelante el "procedimiento", sin concesión de ninguna clase a los "simples particulares" en el momento de sentenciar. La reforma de Diocleciano es apuntalada con la decisión de eliminación de los últimos vestigios de las magistraturas republicanas. Desaparece el antiguo pretor y nace el juez en sentido moderno. Para la toma de esta decisión política, los asesores de Diocleciano advierten que "el sistema formulario", otrora verdadero adelanto en su época, no brinda en ciertos conflictos urgentes una pronta respuesta, perdido en su propia maraña procesal. Destaco que los abogados romanos se convierten, también en este período, en verdaderos especialistas en aletargar el procedimiento cuanto fuere necesario a los intereses de sus clientes, dentro de lo siempre estrictamente permitido por el propio sistema procesal. A esto se debe añadir que por el carácter de la condena, por lo general pecuniaria, la incidencia de la gran inflación que asuela el imperio beneficia con creces al perdedor en el pleito.

A la cuestión política debo agregar la jurídica. Como dijera ut supra, determinadas situaciones necesitan una resolución ágil, si no, en caso contrario, se consuma una injusticia, tal el caso de prestación de alimentos, acciones de estado, pago de honorarios de profesionales, etc.<sup>(101)</sup> Las "medidas extraordinarias" del magistrado inspiran de algún modo que la "resolución jurídica" de la contienda puede ser dada por el propio magistrado, soslayando las instancias procesales pertinentes (pretor-juez-pretor). Surge, entonces, el sistema "extraordinario" (cognitio extraordinem),

plasmado en la actividad única del magistrado destinada al "conocimiento del asunto en litigio y el dictado de la sentencia respectiva", desapareciendo el juzgador privado<sup>(102)</sup>.

El nuevo orden procesal presenta como rasgo singular que el actor solicita la intervención del magistrado. Este último, una vez que escucha el reclamo y la posición del demandado, que es citado a su presencia a tales efectos, recibe la producción de las pruebas ofrecidas por los litigantes y luego, sin la necesidad de designar un "juez privado", emite un decreto (decretum), que tiene el mismo valor que una sentencia (sententia)<sup>(103)</sup>.

El nuevo orden procesal, evidentemente, ofrece la ventaja respecto del antiguo procedimiento "por fórmulas" de la mayor celeridad que le imprime al proceso la sustanciación de la causa en una única instancia y persona, resultando más ágil la tramitación<sup>(104)</sup>. Finalmente, una constitución de los emperadores Constancio y Constante, del año 342, dispone la supresión definitiva de la "fórmula" e impone el nuevo sistema "extraordinario" (cognitio extraordinem)<sup>(105)</sup>. Incluso, siendo ahora una función privativa del Estado "impartir justicia", aparece el principio procesal de "que toda sentencia que parezca injusta puede ser apelada ante un juez superior". El otro carácter del nuevo sistema es la escritura en los actos procesales más relevantes.

## XI. EL PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO (COGNITIO EXTRAORDINEM)

El nuevo sistema, como dijera, presenta particularidades definidas que lo diferencia del anterior. Así, "la posibilidad de la celebración del litigio sin la presencia de la parte demandada, o sea en rebeldía; la eliminación de la in ius vocatio en la forma de citación de la contra, parte por la de la litis denunciatio y la libellus conventionis; la reducción de los efectos de la litis contestatio del procedimiento formulario; la atenuación de las graves consecuencias de la plus petitio; la escritura que se va imponiendo lentamente en la mayor parte de las actuaciones judiciales, como el secreto que en general sustituye a la publicidad característica del procedimiento formulario; las costas procesales, o sea, los gastos de justicia (los honorarios a los abogados, los oficiales del juez, son a cargo del vencido); la supresión de la pecuniariedad de la condena, que es propia del anterior procedimiento, ya que ahora el vencido puede ser condenado a lo realmente peticionado; la duración máxima de los juicios, salvo los referentes al derecho fiscal o a las funciones públicas, que no pueden prolongarse por más de tres años desde el momento de la litis contestatio"<sup>(106)</sup>.

Analizando con mayor profundidad estas reformas, he de decir que el primer tramo del "procedimiento extraordinario" se conoce como "notificación de la litis" (litis denunciatio). Consiste en el modo de efectuar la citación y comparencia de las partes. El proceso da inicio con la redacción del actor de un escrito dirigido al demandado, en donde le especifica la citación que articula contra él. El magistrado debe aceptar o negar la citación del demandado. En el primer supuesto, ordena que el emplazamiento se lleve a cabo por medio de una orden de comparencia del accionado a su presencia (evocatio). La orden es transmitida al demandado por medio de los funcionarios del lugar del domicilio del demandado y, si este último es desconocido, por medio de bandos que un heraldo lee en espacios públicos (edictis)<sup>(107)</sup>. El funcionario, subalterno del juez, acompaña al actor dando fe de la diligencia de notificación (nos aproximamos al sistema moderno de notificación mediante oficiales públicos)<sup>(108)</sup>. Luego de la citación, si el demandado no comparece, el juicio continúa en rebeldía; en cambio, si es el demandante quien no lo hace, el magistrado puede dar por decaído el reclamo o demanda<sup>(109)</sup>. Posteriormente, Justiniano introduce modificaciones al sistema de notificación por el cual éste pasa a denominarse "procedimiento por libelo" (libellus conventionis)<sup>(110)</sup>. Este nuevo sistema es similar al anterior, pero presenta las siguientes singularidades. El actor redacta por sí mismo o por medio de un tabulario un escrito con copias (libellus conventionis) dirigido al juez, en donde expone en forma breve hechos, causa, objeto y naturaleza de la pretensión, pidiendo también que se ordene su traslado al demandado. El juez debe analizar el instrumento y aceptar o denegarlo. Como en el sistema anterior, si el juez lo deniega, finaliza la instancia allí, y si, por el contrario, lo acepta, procede a la notificación del demandado mediante la intervención de un funcionario subalterno (executor) que lleva a cabo la notificación, dejando constancia de la fecha de recepción por el demandado, y si éste acepta o rechaza el libelo<sup>(111)</sup>.

La defensa del demandado (libellus contradictionis) "debe presentarse dentro del plazo de diez días, elevado luego a veinte, previa caución que debe prestar al recibir la copia de la demanda (libellus conventionis) de comparecer ante el juez. Si no comparece, es declarado rebelde,

perdiendo el derecho de interponer recurso de apelación contra la sentencia, sólo puede oponer un recurso llamado de oposición"<sup>(112)</sup>.

Finalmente, el otro modo de notificación de la demanda es "por rescripto"<sup>(113)</sup>, "en el cual el actor no se presenta ante el magistrado, que debe intervenir según las reglas de competencia, sino que acude directamente ante el emperador, para que le designe un juez. Éste lo hace mediante un rescripto, que debe ser notificado al demandado (edictio rescripti)"<sup>(114)</sup>.

Producida la comparecencia del demandado y resueltas previamente las excepciones que éste pudiera articular<sup>(115)</sup>, nos encontramos en la litis contestatio del "procedimiento extraordinario". Ésta es distinta a la del sistema del "procedimiento formulario", por cuanto "se manifiesta como el primer debate contradictorio realizado ante el magistrado con el que queda trabado el litigio (litisinchoata)"<sup>(116)</sup>, produciendo "la vinculación entre las partes entre sí, y ellas con el magistrado, creando la situación procesal conocida con el nombre de litis pendencia, en virtud de la cual el accionante se encuentra imposibilitado de entablar nuevamente la misma acción ante otro magistrado hasta que la primera no hubiera concluido. Además, hace nacer para el demandado la obligación de contestar la demanda y concurrir personalmente o por apoderado a las demás diligencias procesales, y para el actor la de proseguir las tramitaciones hasta su total terminación, bajo pena de hacer incurrir a cualquiera de ellos en rebeldía. También produce el efecto de dejar sentada la competencia del tribunal y los términos en que la litis queda trabada, pues ya no puede afectar ni influir al proceso cualquier hecho posterior, aunque tenga una íntima relación con la demanda"<sup>(117)</sup>. La nueva litis contestatio "precisa el momento en que se considera planteada la verdadera cuestión litigiosa, porque con ella queda fijado el fondo de la cuestión y, en consecuencia, trabado el litigio entre demandante y demandado. Además, sirve para determinar el momento en que vencen los tres años establecidos como duración máxima de un juicio, lo que interesa fundamentalmente para evitar la caducidad de la instancia que se produce indefectiblemente al fenecer dicho término, y con ello la anulación de todas las actuaciones hasta entonces llevadas a cabo"<sup>(118)</sup>.

# FRANJA MORADA

## XII. PRINCIPALES MEDIOS DE PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO

Una vez trabada la litis, se produce la prueba ofrecida por las partes. Entre los principales medios probatorios tenemos los siguientes: instrumental, pericial, testimonial y las presunciones<sup>(119)</sup>.

### 1. Prueba instrumental

Este tipo de procedimiento asigna pleno valor a la prueba instrumental, que puede ser considerada de dos tipos diferentes:

a) Instrumento público. Éstos pueden ser de dos clases diferentes. Por un lado tenemos la documental redactada por "oficiales públicos", que poseen el "derecho de levantar actas" (ius actorum conficiendorum), esto es, aquellos que ejercen cargos judiciales. Este tipo de documento es conocido como "acta", "gesta", etc., y hace plena prueba de los hechos y declaraciones que refieren, pero pueden ser atacados de falsedad.

Por otro lado, también existe otro tipo de documentos públicos llamados confecta, que son redactados por los "notarios" (tabelliones), que son particulares que ejercen la actuación notarial sin ser oficiales públicos y que dan fe pública de los actos que pasan delante suyo por estar sujetos a reglamentaciones controladas por los magistrados. Su principal actividad es la redacción de contratos y testamentos, y actúan por lo general en lugares públicos (v.gr., foro, plazas, pórticos, etc.). Este tipo de instrumento otorga plena fe en juicio, siempre y cuando el notario lo hubiera confirmado mediante juramento ante el magistrado (apud acta).

b) El otro tipo de documentos es el "instrumento privado" (chirographa, cautiones, etc.), redactados por particulares con firma de testigos. Incluso si estos últimos superaban la cantidad de



tres, el documento adquiriría la validez de "cuasi público" (quasi publice scripta), con un valor similar a los redactados por los tabellionis. Su valor probatorio se encuentra sujeto al reconocimiento como auténticos por las partes y testigos firmantes, mediante juramento, o por cotejo efectuado por peritos (comparatio litterarum)<sup>(120)</sup>.

Debo dejar en claro la diferencia entre tabelliones (particulares que ejercen la actividad notarial, similar a nuestros notarios o escribanos) y tabularii (funcionarios públicos a cargo de los archivos municipales que expiden testimonios de documentos que se encuentran a su cargo e intervienen en diversos actos para darle autenticidad)<sup>(121)</sup>.

## 2. Prueba pericial

La prueba pericial es utilizada en forma variada. De este modo, tenemos la "caligráfica" (manus collatio) para constatar firmas; "agrimensores" (gromatici), para la división y la fijación de límites en las propiedades en disputa; "médicos y comadronas" (obstetrices), para determinar el estado de embarazo.

## 3. Prueba testimonial

La prueba testimonial merece un trato aparte, por cuanto debo señalar que ésta es gravitante en todo "acto jurídico romano", pero pierde su antigua relevancia por haber caído en descrédito ante los abusos cometidos a su respecto. Esto motiva que se legislara al respecto para que mantenga el significado y valor necesarios como medio de prueba. En un principio se niega validez probatoria a la declaración de un solo testigo, sin consideración de sus cualidades personales (unus testis, nullus testis); también se determinó que la prueba testimonial debe ceder preponderancia ante la instrumental.

Por su parte Justiniano, preocupado por el tema, legisla y reglamenta sobre esta prueba; así, respecto de las cualidades y requisitos para ser testigo, tachas de idoneidad, inhabilitaciones por parentesco, obligatoriedad de concurrencia ante la citación (carga pública), prestación de juramento, formas de interrogar y reinterrogar, cantidad de testigos, etc<sup>(122)</sup>.

## 4. Las presunciones

En cuanto a las "presunciones" (praesumptiones), se admiten cuando los hechos en disputa no pueden probarse directamente por testigos, documental, pericial, etc. Es una prueba de "indicios", es decir que el juzgador forma su convicción mediante elementos que le proporciona la ley o surgen de la litis que lo inducen al momento de sentenciar. Las presunciones pueden darse "por la ley" (iuris) o "por el juez" (hominis).

Las primeras (iuris) son de dos clases: "de pleno derecho" (iure et de iure), es decir que no admiten prueba en contraria, por cuanto es la propia ley la que la indica. Y las "que no lo son" (iuris tantum), que admiten prueba en contrario.

Las segundas (hominis) son las originadas por la simple labor intelectual del juez de acuerdo con las probanzas del pleito, sin sujeción a normativa alguna<sup>(123)</sup>.

## 5. La sentencia

Es la decisión adoptada por el juez una vez concluida la instancia de prueba y después de que se registra todo lo actuado en un "protocolo". El juez arriba a ella después de valorar la prueba rendida y teniendo en consideración los hechos y derecho invocados por las partes. La sentencia debe ser escrita en latín o griego (recordemos que después de la división del imperio, el griego pasa a ser idioma oficial junto al latín) y leída públicamente por el juez (o por alguien en su nombre, según los casos) en presencia de las partes, sus asesores legales y demás funcionarios del tribunal. El plazo para dictaminar no puede superar el tope de los tres años dispuesto como duración de todo juicio, salvo que una instancia judicial superior le ordene al juez un plazo determinado para sentenciar. La sentencia debe ordenar expresamente la absolución o condena del demandado y, en su caso, del actor<sup>(124)</sup>. Como he dicho, en este tipo de procedimiento queda superado el principio de que la sentencia debe ordenar el pago de una suma de dinero. Por el contrario, surge el concepto de que la sentencia debe ordenar lo que se pide concretamente (v.gr., la entrega de una cosa determinada), y, de no ser posible el cumplimiento de la prestación debida, se debe ordenar pagar una suma de dinero en justipreciación de lo condenado, pero hasta un tope del doble de su valor. Para finalizar, el juez debe expedirse respecto del monto e imposición de las costas (gastos y honorarios de los abogados y peritos del pleito), bajo pena de estar obligado a pagarlo de su propio peculio<sup>(125)</sup>.

Ahora bien, si el caso en examen supera la actividad intelectual del juez, o entiende que no es de su competencia, éste está facultado a elevarla al emperador (consultatio), previa notificación de la decisión a las partes, quienes tienen un plazo para refutar el criterio adoptado por el judicante. Luego, todas las actuaciones son elevadas al emperador, quien puede resolver el asunto en persona o delegarlo en alguno de sus magistrados superiores. Esta instancia no tiene plazo alguno para emitir el veredicto final, sólo las partes pueden peticionar, transcurrido un año, "que se tome prontamente la decisión". La sentencia del emperador (rescripto) es inapelable (similar a un fallo de la Corte Suprema de Justicia)<sup>(126)</sup>.

## 6. Los recursos

La sentencia definitiva dictada por el juez y que no es motivo de consultatio puede ser apelada por la parte que no satisface sus intereses. Esto es una innovación dentro del sistema procesal romano, que surge ante la necesidad de lograr "una mejor impartición de justicia", debido a la proliferación de sentencias injustas que dejan a gran cantidad de justiciables insatisfechos. Al respecto, Justiniano dispone un plazo perentorio de diez días corridos para que se articule la apelación, que puede ser verbal o escrita (libelli appellatorii). La apelación puede ser concedida o denegada por el juez. En el primer supuesto es elevada al superior, y en el segundo se debe recurrir "en queja" ante éste. Si la "queja" prospera, es decir que el recurso fue mal denegado, se aplica una severa sanción al juez, y si acontece lo contrario, ella se aplica al apelante en queja.

Concedida la apelación, ésta tiene carácter suspensivo (detiene la ejecución de la sentencia hasta tanto se resuelva la apelación). El magistrado superior debe ocuparse de ésta y ordenar la sustanciación de un proceso similar al de primera instancia (debate, alegaciones y pruebas). Justiniano permite la "alegación de hechos nuevos" en segunda instancia, y "producir nuevas pruebas al respecto", lo que implica que el superior puede efectuar una nueva sentencia con hechos y pruebas distintos de los debatidos en primera instancia. El límite impuesto es que no se puede alegar ni aplicar en segunda instancia una ley dictada con posterioridad a la vigente al originarse la contienda. El plazo de sustanciación de la instancia de alzada tiene un máximo de dos años. El que resulta vencido en el recurso debe hacerse cargo de las costas del proceso, cuya modalidad varía según las épocas. Así, Diocleciano ordena el pago del cuádruplo de las costas originales. Luego, Constantino, ante la proliferación infundada de los recursos (se pueden interponer hasta tres apelaciones), simplemente para ganar tiempo y beneficiarse con la "inflación", ordena que el derrotado debe ser condenado al destierro por dos años y la confiscación de la mitad de sus bienes, y si es indigente, a realizar "trabajos forzados". Justiniano deja sin efecto estas brutales penalidades,

disponiendo el pago de sumas dinerarias sujetas al arbitrio del juez de acuerdo con la naturaleza del juicio y la conducta procesal que asumiera el vencido.

Los recursos finalizan con estas tres apelaciones o, en su defecto, si media en cualquier momento una decisión adoptada por el emperador, o por el "prefecto del pretorio"<sup>(127)</sup>.

## 7. La ejecución de la sentencia

Una vez que la sentencia quede firme, es decir, que pasa a tener autoridad de "cosa juzgada", el vencedor tiene la vía expedita para solicitar su cumplimiento. Si el vencido cumple con lo ordenado por el juez (pretensiones y costas), el juicio finaliza de modo definitivo. Para esto cuenta con un plazo máximo de cuatro meses. Fenecido este plazo, si el obligado por sentencia no cumple con ella, se inicia la "vía de ejecución" (actio iudicati) para que coercitivamente se logre el cumplimiento ordenado por ésta. Como dije, la sentencia debe ordenar el cumplimiento de aquello realmente adeudado —v.gr. entregar una cosa (dare) o cumplir con un hecho (facere)—, y únicamente en caso de imposibilidad de cumplimiento material se reemplaza mediante dinero.

Para el caso de deudores insolventes y de mala fe se dispone el encarcelamiento, pero no como toma en prenda, según las vetustas disposiciones de la ley de las XII Tablas, sino mediante detención en establecimientos públicos bajo custodia del Estado (cárceles, establecimientos militares, etc.). Quedan exceptuados de esta modalidad quienes tienen una numerosa prole y también los que ceden sus bienes al empleador o solicitan a éste una moratoria especial<sup>(128)</sup>.

La ejecución contra los bienes del deudor es similar al "sistema procesal anterior", es decir que si se trata de la entrega de "un bien determinado" se ordena su apoderamiento por funcionarios del magistrado y la entrega posterior al acreedor (sólo en caso de imposibilidad material se sustituye en dinero); por su parte, si la ejecución es dineraria, se toman bienes del moroso (muebles, inmuebles, derechos) por funcionarios públicos, y si éste no abona en el término perentorio de dos meses, se los subasta públicamente al mejor postor.

Para el supuesto de que fueran varios los acreedores, la ejecución tiende a garantizarle el cumplimiento de la sentencia a todos ellos, por eso se abre el "concurso" (antecedente del actual concurso o quiebra comercial), que se implementa por la bonorum venditio respecto de todo el patrimonio del deudor, mediante la cual los acreedores adquieren la posesión de los bienes del deudor y nombran un administrador (curator bonorum), que debe proceder a la venta de los bienes. Previo a ello debe aguardar la presentación ordenada de los acreedores según los siguientes plazos: dos años para los presentes y cuatro para los ausentes. La venta no se lleva a cabo en bloque, sino objeto por objeto (distractio bonorum). Luego, el producido de la subasta se distribuye entre los acreedores, percibiendo el crédito primero los acreedores privilegiados y luego a prorrata por los demás<sup>(129)</sup>.

## 8. La representación y la defensa en juicio

Para que la invocación y demostración del derecho de los litigantes se lleve a cabo del mejor modo, garantizando su debida defensa, es necesario la presencia de los abogados (advocatus), y así lo ha entendido el derecho romano.

A pesar de que en la época primitiva los jefes de familia se encargan de enseñar el derecho a los integrantes de su grupo familiar, no todos conocen profundamente las normas legales que rigen, y menos aún, tener la dialéctica, sabiduría y aptitudes suficientes como para hacer valer sus intereses; encarar una demanda o una defensa, e influir en el ánimo del juez como lo puede hacer un abogado, verdadero conocedor del derecho<sup>(130)</sup>. Por lo demás, ante la evolución permanente del derecho y "la ignorancia a las leyes no sirve de excusa, no todos los habitantes de Roma, como en la actualidad, pueden seguir sus pasos, por lo menos en la forma que les permita

defender adecuadamente sus pretensiones. Nadie mejor que un abogado para dar apoyo a un indefenso y más brillo a la Justicia"<sup>(131)</sup>.

Antiguamente, en el sistema de "las acciones de la ley", los litigantes son asistidos jurídicamente por personas entendidas en el tema (padroni), que se limitan a aconsejarlos<sup>(132)</sup>. Éstos desempeñan su función de modo honorífico y gratuito; sin embargo, los clientes satisfechos con sus servicios pueden y acostumbran a recompensarlos mediante la entrega de un donativo (merced o dádiva)<sup>(133)</sup>.

En el sistema formulario, tras la configuración de Roma en Imperio, la actividad se torna remunerada. Desaparecen los padroni, y son reemplazados por verdaderos jurisconsultos, llamados "abogados" (advocati)<sup>(134)</sup>.

Aun así, los advocati, al igual que los padroni, no representan al litigante, sino que sólo lo asesoran y acompañan ante el Tribunal. La función de representar está reservada a los "procuradores" (procuratores y cognitores), que aparecen más tarde, cuando es necesaria la creación del "representante de ausentes" ante el auge que toma la ciudad de Roma. Por su parte, la función de los "patronos" y "abogados" existe desde antiguo<sup>(135)</sup>.

La actividad específica del "abogado" en la etapa "de derecho" del "procedimiento formulario" sustanciada ante el pretor tiene carácter eminentemente jurídico, puesto que lo ayuda a seleccionar y a redactar la fórmula y lo aconseja sobre la interposición de las excepciones, defensas y prescripciones. En la segunda etapa (apud iudicium), llevada a cabo ante el juez, árbitro o tribunal, los abogados brindan asesoramiento sobre la presentación de la prueba de acuerdo con los hechos indicados en la fórmula y primordialmente exponen verbalmente las conclusiones de hecho y de derecho en favor de su parte (postulare). Mas luego comienzan paulatinamente a diluirse las figuras del cognitor y el procurator y aparece con mayor nitidez y fuerza la del abogado (advocatus), que, con su actuación, incluso reemplaza a aquéllos. Los abogados reciben también la denominación de "jurisperitos" (iurisperiti), "escolásticos" (sholastici) y "togados" (togati)<sup>(136)</sup>.

La actividad de los abogados es prolíficamente reglamentada mediante disposiciones dictadas a través de los siglos y luego recogida en el Código Theodosiano y en el Corpus Iuris Civile<sup>(137)</sup>. Así, no pueden ejercitar la actividad los que se encuentran en edad pueril, los sordos y ciegos, las mujeres, los condenados a la pena capital, los calumniadores, los que fueron sancionados con penas infamantes, los no cristianos y los sodomitas<sup>(138)</sup>.

De igual modo, el abogado tiene que cumplir deberes y obligaciones inherentes al desempeño de la actividad. Por lo tanto, es responsable civil y penalmente por sus actos y merece hasta la pena de "infamia" si falta a los deberes de fidelidad y honestidad. Tiene prohibido utilizar frases injuriosas, prolongar maliciosamente los pleitos, lucrar indignamente y dejarse llevar por el afán del dinero. Debe rendir cuentas de lo que ejecuta y de lo que se obliga a ejecutar, como así también de las cantidades recibidas, respondiendo por dolo y culpa en su caso<sup>(139)</sup>. También se le impone la obligación ética y moral de no hacerse cargo de un pleito cuyo resultado le parece de resultado incierto. Se le prohíbe adquirir el pleito mediante la cesión de los derechos de su cliente (redemptio), pactar honorarios en un todo o en parte del resultado de la litis (cuota litis), convenir únicamente percepción de honorarios en caso de éxito (palmario), etc<sup>(140)</sup>. Se castiga severamente con la pena de "infamia" al abogado que ejerza la defensa de ambas partes en el pleito (prevaricato), como así también al que incurra en soborno y depredación<sup>(141)</sup>.

Es de destacar que en el Bajo Imperio la ciencia y enseñanza del Derecho se confía a los propios abogados, gozando de privilegios en razón de sus estudios, como ser designados árbitros en el lugar donde ejercen su profesión, examinar cuentas, la no imposición de cargos, etc<sup>(142)</sup>. Finalmente, cuando concluyen su actividad como abogados, se los nombra "condes de primer orden" en reconocimiento a la fidelidad y talento que demostraron en defensa de sus asistidos<sup>(143)</sup>.

Por último, es bueno señalar que durante el período justiniano los abogados se encuentran organizados en colegios (collegia), que consisten en corporaciones de carácter gremial destinadas a la vigilancia del desempeño con decoro de la profesión y a la defensa de los intereses de sus miembros. Los colegios cuentan con un número de cincuenta integrantes, aproximadamente, existiendo uno en cada prefectura. Para formar parte de un colegio se exige haber cursado de modo reglamentario los estudios de jurisprudencia y una certificación juramentada de sus profesores dando fe de su instrucción en la ciencia del derecho<sup>(144)</sup>.

En suma, el ejercicio de la actividad de abogado en Roma está muy bien visto y merece una profunda estima social. Incluso para la defensa de los intereses del fisco se requieren los servicios de aquellos abogados más notables en el ejercicio de la profesión, colmándolos de grandes honores y dignidades<sup>(145)</sup>.

## 9. Retribución del abogado

Como dijera, en un principio la actividad es gratuita, aunque luego se abre paso la idea de percepción de un pago por el trabajo realizado. La evolución es paulatina, detectándose a fines de la República que, debido a la creciente complejidad que presentan los pleitos, se comienza a hacer entrega al abogado de una liberalidad de cierto valor al finalizar su trabajo<sup>(146)</sup>. A principios del Imperio la actividad del abogado se encuentra delineada como una profesión liberal, fijándose honorarios que se abonan al finalizar el litigio<sup>(147)</sup>. De este modo, Claudio determina la fijación de honorarios máximos por el desempeño del abogado. Alejandro Severo legisla que los honorarios deben ser fijados por el juez en cada pleito en particular, teniendo en cuenta la costumbre del Tribunal, la sabiduría del abogado y la naturaleza del juicio, prohibiendo todo pacto de cuota litis. También el mismo emperador otorga una acción extraordinaria (cognitio extraordinaria) para que el abogado pueda ejecutar los honorarios impagos<sup>(148)</sup>. Diocleciano, por su parte, fija regulaciones máximas para el servicio del abogado, determinando un tope de doscientos cincuenta denarios por una postulatio y en mil denarios por una cognitio. Constantino, a su vez, ratifica la prohibición de celebrar pactos de cualquier naturaleza que fueren entre el abogado y su cliente, limitándose aquél tan sólo a la percepción de los honorarios regulados por el juez<sup>(149)</sup>. Valentiniano y Valente, más adelante, continúan con la reiteración de esta prohibición<sup>(150)</sup>. El derecho justiniano mantiene la misma tesitura que sus antecesores y fija honorarios máximos de cien áureos por cada causa<sup>(151)</sup>.

En mi opinión, es bueno destacar que en forma paralela a la configuración de los honorarios y su necesidad de regulación por el órgano de aplicación, también se abre paso la consideración de su obligatoriedad. Prueba de esto último son las acciones creadas para garantizar la percepción de los honorarios por parte de los abogados. La obligación del pago de los honorarios descansa, en un principio, especialmente en una cuestión de honor, más que en un fundamento de costreñimiento jurídico. Por consiguiente, es necesario legislar lentamente la cuestión ante el creciente número de morosos al respecto<sup>(152)</sup>. Es Claudio quien, luego de fijar honorarios máximos para el abogado, autoriza a éste a accionar contra su cliente por honorarios impagos mediante un requerimiento especial o extraordinario (cognitio extraordinaria). Éste se interpone ante un pretor especial en la ciudad de Roma, o directamente, ante los gobernadores en las provincias, quienes deciden, una vez escuchadas las partes, fijando el monto de los honorarios en disputa<sup>(153)</sup>.

Debo hacer hincapié en que el jurista primitivo, que luego se transforma en el advocatus, ha devenido en nuestro abogado actual<sup>(154)</sup>. Esto se advierte claramente en el análisis de la evolución del modo del desempeño de la actividad del abogado, sus responsabilidades y deberes, su importancia social, etc. Basta recordar la actual colegiación obligatoria, el poder de fiscalización de los colegios de abogados, las condiciones legales para ejercer la profesión, las responsabilidades y deberes del abogado para con su asistido, el trato y el respeto al colega y la problemática de la percepción de los honorarios para darnos cuenta de la injerencia e impronta del derecho romano en temas de actualidad<sup>(155)</sup>.



#### I. CARACTERES GENERALES. PRINCIPALES DELITOS. PENAS. PROCEDIMIENTO

a) Hablar de derecho penal romano es un tema basto y complejo que escapa a los objetivos de este libro, pero, a mi juicio, parece menester realizar una breve consideración al respecto, por cuanto lleva consigo la finalidad de demostrar que el derecho romano no guarda sólo relación con el derecho civil, como se cree erróneamente, sino que, por el contrario, abarca todo el amplio espectro del derecho positivo, conformándolo, en contraposición histórica, justamente con el derecho canónico.

Pues bien, en primer lugar debo precisar qué entiende por delito el derecho romano. Para este último, delito es todo hecho que produce un daño a una persona. El daño puede ser sobre la persona o respecto de sus derechos. El hecho debe ser voluntario y contrario a la ley. Justamente, por constituir un ilícito, merece ser castigado mediante una pena. Los delitos son de carácter público o privado.

Se consideran delitos públicos los que afectan el tejido social y la sanción es aplicada por autoridades de la organización pública. Someramente, la evolución de este tipo de delitos es la siguiente.

En el derecho antiguo, la ley de las XII Tablas castiga la alta traición a la patria (perduellio), el falso testimonio, el soborno al juez, el asesinato de un padre de familia (parricidium), el perjurio, el incendio, la hechicería, la sátira difamatoria<sup>(2)</sup>, etc.

En el derecho clásico se añaden a los indicados precedentemente otros, como el atentado contra la república o el emperador (lex Iulia maiestatis), la falsificación de un sello oficial (lex Corneliae falsis), el robo de cosas públicas o sagradas (lex Iulia de peculatus), la exacción ilegal y el cohecho (lex Iulia repetundarum), la malversación de caudales públicos (lex Iulia de residuis), el adulterio y el estupro, el ultraje a las costumbres, el proxenetismo, el matrimonio incestuoso (todos punidos por la lex Iulia de adulteriis), el homicidio intencional y el envenenamiento y su agravamiento cuando la víctima es un ascendiente o descendiente (lex Cornelia de sicariis y lex Pompeia de parricidis), la violencia cometida con o sin armas (lex Iulia de vis publica et privata), la violación de la prohibición del Estado de exportar trigo (lex Iulia annonae) y la prohibición de compra de votos de los electores que deben elegir los magistrados (lex Iulia de ambitu)<sup>(3)</sup>.

En el Bajo Imperio aparecen otros tipos de delitos públicos, que se suman a los expuestos, y se encuentran ligados a las decisiones imperiales y a lo religioso, a saber: el engaño (stelionatus), el rapto (raptus), el cohecho (conscussio), el encubrimiento (crimen receptatorum), el aborto (abactus partus), la exposición (expositio infantium), la blasfemia, la perturbación a los oficios divinos, la apostasía, la herejía<sup>(4)</sup>, etc.

Otros delitos que han sido tipificados, desarrollados y sancionados por el derecho penal romano a lo largo de su devenir histórico son, entre otros, los siguientes: envenenamiento mediante filtro amoroso, la castración, la sedición, el daño causado violentamente en la propiedad ajena, la apropiación violenta, el abuso de cargo público, la falsificación, la estafa, la bigamia, el rapto, la aceptación de dádivas y extorsiones ejecutadas por agentes y funcionarios públicos, la concusión, el cohecho, la defraudación impositiva, el hurto de bienes privados, el hurto entre cónyuges, el hurto de cosechas, el hurto de herencias, el daño en los sepulcros, el daño en los templos, el daño en la propiedad pública, el daño en la propiedad privada, el daño causado por esclavos y animales, la tenencia de animales peligrosos, el daño causado por cosas arrojadas, el incumplimiento de las obligaciones correspondientes a los poseedores de inmuebles (v.gr., la prohibición de tener hornos crematorios, sepulcros y tejares dentro de la ciudad, la restricción de demoler casas), la usura respecto al dinero, grano y mercaderías, el abuso de los derechos industriales y mercantiles, el abuso del estado civil (v.gr., la venta fraudulenta de un hombre libre haciéndose pasar por esclavo

participando de la ganancia, el concubinato de una mujer libre con un esclavo, la revocación de la manumisión por causa de ingratitud), las usurpaciones de los estados de libertad, ingenuidad y ciudadanía, los abusos electorales, los abusos del derecho de asociación, los abusos de denuncias fiscales, las irregularidades en el ejercicio de las funciones públicas, en el ejercicio del cargo de jurado, etc.

Son delitos de carácter privado cuando se produce un daño en la integridad de la persona o su patrimonio y son castigados mediante sanciones pecuniarias. Brevemente, la evolución de este tipo de delitos es la siguiente.

En tiempos antiguos, la ley de las XII Tablas castiga la injuria (iniuria), el hurto (furtum) y los ataques contra los bienes de una persona sin propósito de lucro (damnum iniuria datum)<sup>(6)</sup>.

Durante el derecho clásico los delitos privados expanden su consideración y aplicación; así, la injuria (iniuria) se extiende a los daños de carácter moral; el hurto (furtum) a la usurpación, despojo de herencias y de la posesión, y el damnum iniuria datum da paso a la lex Aquiliae. También surgen los denominados "delitos pretorianos", es decir, creados por el pretor, entre los cuales puedo citar aquellos relacionados con los vicios de la voluntad, a saber: el dolo (dolus), la violencia (metus) y el fraude a los acreedores (fraus creditorum)<sup>(6)</sup>.

Análisis especial merece el daño producido por cuadrúpedos que, en fundamento a su falta de raciocinio, es considerado como injuria (iniuria)<sup>(7)</sup>.

En el Imperio tenemos la aparición de los siguientes delitos: el robo con fractura, el robo en baños públicos, el asalto en los caminos con inclinación al asesinato, el saqueo, el abigeato, los escritos difamatorios y calumniosos, la perturbación a la paz doméstica<sup>(8)</sup>, etc.

En cuanto a la pena, debo decir que en tiempos remotos el castigo se encuentra vinculado con lo divino, consistiendo en la expulsión o segregación del culpable del núcleo social al que pertenecía, en razón de su ofensa a los dioses; pero más adelante, con la evolución y crecimiento de Roma, la punición pierde el tinte religioso y deja paso a la idea de que debe perseguir al delincuente, que debe padecer similar daño al producido a la víctima. El quantum del castigo queda a voluntad del padre de familia, que es el encargado de la punición doméstica. Todos los integrantes de la familia que se encuentran bajo su poder, ya sean hijos de familia, mujeres, esclavos, etc., se encuentran sujetos a dicha punición. Luego, consolidada la forma de gobierno de la civitas, la potestad de punir le es quitada a los padres de familias (esfera privada) y queda como facultad exclusiva de la autoridad estatal (esfera pública). Ésa es la culminación de delito y pena, por cuanto surge la idea de que deben ser establecidos por la ley y aplicados por los órganos estatales (juez).

La evolución del castigo guarda relación con el desarrollo de Roma, es decir, el momento social y político por el cual transita. En consecuencia, encontramos sanciones de tipo pecuniario, corporal y hasta moral<sup>(9)</sup>.

Las penas aplicables son de la más diversa índole; así, tenemos a cargo de los jueces la pérdida de la libertad (introducida por Tiberio en el 23 a.C.) con o sin trabajos forzados (galeras y minas), y mediante cumplimiento en cárceles públicas y escuelas de gladiadores; la multa; la caída en esclavitud de los ciudadanos que hubieran violado las normas de disciplinas militar o por haber facilitado ayuda al enemigo y la deportación. Además, en manos de los censores, tenemos la imposición de la tacha censoria y de infamia, como se ha visto en su oportunidad.

Es interesante aclarar la situación jurídica de aquellos que son castigados mediante la pérdida de la libertad. Se los considera "esclavos de la pena" (servus poenae), lo cual implica que dejan de formar parte de su familia, pierden las relaciones matrimoniales, sus bienes pasan a pertenecer al Estado juntamente con su persona, se los declara incapaces para adquirir bienes en lo sucesivo, como también disponer de ellos de cualquier modo, ya sea inter vivos o mortis causa.

Párrafo breve merece considerar especialmente la pena "de muerte" y la "interdicción del agua y del fuego".

En primer término, la aplicación de la "pena de muerte" es de antigua data en Roma. Se lleva a cabo mediante horca, decapitación, hoguera, crucifixión, trabajo en las minas, etc. Luego, la evolución cultural romana considera que es impropio aplicarla y se reemplaza por las penas de azotes, o apedreamiento (fustuarium). Más tarde, las penas corporales indicadas pueden ser conmutadas por el destierro voluntario del condenado (v.gr., "interdicción del agua y del fuego"<sup>(10)</sup>).

Pero es interesante señalar que en el "derecho penal bizantino" es frecuente el empleo de la "mutilación" como castigo (v.gr., ceguera, corte de la nariz, pérdida de la mano, la lengua, etc.); y en algunos casos, con la particularidad de que es infligida tras la aplicación de "la pena de muerte".

Por su parte, la "interdicción del agua y del fuego" es también de suma aplicación en la Antigüedad y en Roma. Sus fundamentos son atávicos, por cuanto siendo el ser humano por excelencia gregario, tiene un sentido innato de permanencia con el núcleo social en que desarrolla su vida. Se ha debatido al respecto que el hombre, si no es en sociedad, quizá no puede vivir, de aquí las consideraciones sutiles respecto de la obra Robinson Crusoe de D. Defoe. Esta pena tiene origen en los clanes de la época cavernaria, en donde se expulsa del grupo al considerado indeseable, implicando sutilmente una pena de muerte para con él, en virtud de que, al aislarlo del grupo social en el cual convive, tiene un futuro de muerte (la soledad, la falta de agua, alimentos y del calor del fuego apuntan a ello). La "interdicción del agua y del fuego" consiste en Roma, entonces, en el confinamiento del culpable de un delito en un lugar distante (deportatio) o, de acuerdo con otra variante, la confinación del condenado a una isla en donde debe mantener residencia fija (relegatio)<sup>(11)</sup>. Esta pena implica la pérdida de la ciudadanía, la venta de su patrimonio y el apercibimiento de muerte para el caso de que regrese al territorio romano.

Otro tipo de penas es la privación del derecho de sepultura y de la buena memoria, la pérdida de la dignidad sacerdotal, la pérdida del cargo público, la confiscación patrimonial.

Por fin, es menester aclarar que no siempre se aplicaban penas corporales, sino también de índole pecuniaria mediante la imposición de indemnizaciones fijadas por ley o estimadas por el pretor, según el caso en cuestión.

b) Debo destacar que el poco afecto que tiene el jurista clásico en formular conceptos, teorías y clasificaciones es trasladado también al ámbito penal. En principio, el procedimiento criminal se lleva a cabo por intermedio de un magistrado o por una acción popular.

En los tiempos antiguos, como dijera ut supra, le corresponde al padre de familias castigar a aquellos que se encuentran bajo su poder y violan el derecho del grupo genticilio. Más tarde, también esta potestad se extiende al pontífice máximo. Luego, en la Monarquía, es el rey quien interviene y sanciona cuando se violenta la normativa consuetudinaria que rige la sociedad<sup>(12)</sup>. Esta potestad regia es trasladada posteriormente en la República a determinados magistrados que conocen especialmente del esclarecimiento y sanción de los delitos en razón de competencia que les es propia para ello; v.gr., en el delito de alta traición, los duoviri perduellionis, y en el delito de parricidio, los quaestores parricidii. Debo señalar la importancia de la sanción de la lex Valeria (300 a.C.), que modifica el proceso vigente, introduciendo el recurso de apelación ante los comicios en el caso de imposición de la pena de muerte, por cuanto, hasta la sanción de la mencionada ley, los magistrados ut supra señalados tienen plena facultad para indagar, sentenciar y aplicar la pena capital, cobrando suma importancia su investidura. Después de la lex Valeria pierden injerencia, conservando sólo las facultades instructorias<sup>(13)</sup>.

El sistema romano evidencia un cambio significativo tras la sanción de la lex Calpurnia, propuesta por el tribuno Calpurnio Pisón (año 149 a.C.), que dispone que el pretor peregrino debe estar a cargo de los juicios que versan sobre las exacciones de los magistrados provinciales, creando el primer tribunal permanente denominado "cuestura permanente" (quaestio perpetuae). La citada ley ordena la conformación de una lista de jueces, entre los cuales se deben elegir los integrantes del "jurado" que ha de entender en cada caso en particular bajo la dirección del pretor peregrino. Posteriormente, en tiempo de Sylla, se consolida el procedimiento de los tribunales de las quaestiones perpetuae para la dilucidación de todo tipo de delito.

El proceso es iniciado por cualquier ciudadano. Éste debe acudir en primer lugar ante el magistrado a los efectos de que lo autorice a formular la acusación ante el mencionado tribunal (postulatio). Una vez obtenida la autorización, acude ante el tribunal y realiza formalmente la acusación (accusatio). A continuación se cita al acusado con el propósito de que tome debida nota de la acusación. Una vez notificado el acusado del delito que se le imputa, el magistrado procede a inscribir la causa en el registro del tribunal, fijando el día y la hora de la audiencia en que deben comparecer el acusador, el acusado y los defensores. El día y hora señalado se sustancia la audiencia ante la presencia del magistrado que oficia de presidente del tribunal con la presencia de los involucrados. Si el acusador no concurre, se tiene por desistida la acusación y, en caso contrario, el juicio continúa hasta la condena del acusado en ausencia. Ahora bien, si a la audiencia fijada concurren todos los interesados, el magistrado procede a la integración del jurado, designando a sus integrantes de la lista de ciudadanos inscriptos como jueces.

Luego de que cada parte ejerza el debido derecho de recusación respecto de los jueces designados, se celebra la audiencia, rindiéndose las pruebas pertinentes y los debates.

Entre los principales medios de prueba tenemos la testimonial. Sólo se encuentran habilitados para prestar declaración los hombres libres, y si bien en tiempos muy antiguos estaba permitido el tormento para obligarlos a declarar, después del período republicano se prohibieron los apremios.

Los esclavos también pueden testimoniar en materia penal, pero su declaración no tiene plena validez como la del hombre libre; tampoco se permitió que el esclavo testimoniase en contra de su amo.

Otra de las pruebas permitidas es el registro domiciliario y la incautación de papeles. Estas medidas se encuentran a cargo del acusador, que puede ingresar en la casa del acusado o de terceros a los efectos de consultar la documentación a que hubiera lugar (v.gr., documentos oficiales, libros de cuentas, papeles de negocios de la persona interesada, etc.). Una vez individualizada la documental necesaria como prueba ella es sellada y retirada por el propio acusador, quien debe entregarla en plazo perentorio al magistrado.

Una vez rendidas las pruebas, se llevan a cabo los debates con la debida defensa del acusado.

Finalizada esta etapa procesal, el jurado debe dictar sentencia condenando o absolviendo al acusado. Los votos se emiten en forma secreta en tablillas especiales. El pretor, como presidente del tribunal, es el que debe hacer conocer públicamente el resultado de la votación. Si es absolutoria, el acusado no puede ser sometido a nuevo proceso por el mismo hecho; si es condenatoria, se le impone la pena que corresponda por el delito en cuestión.

Destacan los maestros Peña Guzmán y Argüello que "al lado de los tribunales permanentes de las quaestiones coexisten los comicios y los magistrados con jurisdicción criminal, hasta que las leyes Iuliae de César y de Augusto crearon un armónico ordo iudiciorum publicorum, destinado a configurar la competencia del senado en materia criminal. Como consecuencia, desaparece el poder jurisdiccional de las asambleas populares y el instituto de la provocatio ad populum, mientras el príncipe va asumiendo el derecho de represión (coercitio), que ejerce directamente o por intermedio de los funcionarios imperiales"<sup>(14)</sup>. Más tarde la autoridad del emperador termina por absorber la potestad de punición y, mediante la introducción del sistema procesal de la cognitioextraordinem en materia penal, lentamente desaparecen los tribunales de las quaestiones perpetua, dado que su competencia y funciones se reemplazan por el primero. Este sistema se caracteriza por la libre facultad del juzgador para resolver las causas criminales, quedando sólo reservado para la autoridad pública el inicio y prosecución del procedimiento.

El sistema procesal brevemente expuesto es el que se lleva a cabo en Roma, mas existen otros tribunales con competencia en distintos lugares del extenso imperio; así, las prefecturas itálicas que originan el procedimiento municipal privado y público; el procedimiento criminal en las provincias a cargo del procónsul o gobernador, etc.

## II. EL TEMOR REVERENCIAL Y LA OBEDIENCIA DEBIDA EN ROMA<sup>(15)</sup>

Es muy importante detenerse en este tema, por cuanto se está en la creencia de que éste es producto del derecho moderno. Realmente la raíz misma se encuentra en la jurisprudencia romana. Ello no es extraño, primero por la particular configuración de la familia mediante la figura excluyente y poderosa del pater familias, y después, fundamentalmente por el rol primordial del ejército dentro del Estado romano. Debe recordarse que en un inicio ambas instituciones, familia y ejército, se encuentran singularmente entrelazadas. Es decir que la concepción de autoridad y mando son propios de la sociedad romana y el imperium del magistrado resulta una clara muestra de ello.

De Ulpiano se obtiene el principio jurídico que establece que aquel individuo, hijo (filius), cliente, esclavo, soldado, etc., que obedece la voluntad del pater, señor o superior, carece de voluntad propia, por cuanto debe obedecer o llevar a cabo ciegamente aquello que este último le ordena o encomienda. Es decir que el único responsable del cometido es aquel que da la orden. Y ello debe ser así, por cuanto es una causal de exoneración de responsabilidad de fácil utilización que pueda soslayarse de aquélla imputándosela a quien ejecuta el acto, especialmente si se causa un perjuicio de cualquier índole. Los juristas, alertados de esta posibilidad, claramente dicen que la voluntad es de aquel que da la orden y no del que la lleva a cabo<sup>(16)</sup>.

En igual sentido se expide Paulo, pero con un matiz interesante, puesto que hace hincapié en la "necesidad" de obedecer. O sea que aquel que tiene la obligación de obedecer, enseña Paulo, no puede ser culpado del daño ocasionado, sino quien da la orden para ello<sup>(17)</sup>.

Pero, dada la particular concepción del derecho romano clásico, imbuido de casuismo, encontramos que es el mismo Ulpiano quien asienta una excepción de capital importancia en el

tema cuando señala que se perdonará a aquellos que ejecutan la orden dada por el superior, puesto que la responsabilidad es de éste, siempre que el delito o culpa resultante no sea "atroz".

Se infiere de Ulpiano que cuando el resultado de la orden es ilícito o produce un daño, que puede ser calificado como atroz, el responsable no es sólo el amo o señor, sino también quien lo ejecuta<sup>(18)</sup>.

Ello brinda espacio interpretativo suficiente para considerar que bien ha querido decir Ulpiano que quien recibe una orden atroz puede negarse a cumplirla<sup>(19)</sup>.

Puede verse claramente que una vez más el derecho romano ha dado la pauta de su madurez. Y es así, por cuanto los juristas cargan sobre sus espaldas la intensa experiencia adquirida durante el paso del tiempo, lo cual los conduce a crear y moldear el derecho frente a los hechos cotidianos que se les presentan a su consideración.

Está claro que el principio de autoridad y responsabilidad modernos, unido a la obligación de obedecer, nace en los autores aludidos, pero también origina la facultad de exceptuarse del cumplimiento ante la "atrocidad" del hecho encomendado, por cuanto en este caso la responsabilidad será compartida entre quien da la orden y quien la cumple por no haberse negado a realizarla.

FRANJA  
MORADA



### CAPÍTULO XXVII - DERECHO ROMANO ADMINISTRATIVO

Me he referido en otras oportunidades en esta misma obra a los distintos aspectos que presenta el derecho romano, manifestando que en nuestro país esencialmente siempre se lo vincula al ámbito del derecho privado. Mas, en rigor de verdad, éste es fuente de nacimiento de otras ramas del derecho moderno. Así lo hemos comprobado con el derecho penal, procesal, comercial, etc., y en este acápite he de referirme, aunque brevemente, a lo concerniente al "derecho administrativo romano".

Los juristas romanos se han expedido siempre respecto del "derecho en general" y no solamente a una rama de éste en particular. Por tal motivo me ha interesado investigar en las fuentes y en la doctrina lo concerniente al "derecho administrativo", por cuanto éste hace al Estado, y los romanos elaboran toda una égida legal para regular su marcha. En este sentido, Bello Janeiro sostiene en el Prólogo de la magnífica obra sobre el tema, a cargo de la dirección del maestro romanista español Antonio Fernández de Buján, que "el derecho administrativo y la Administración son, ante todo, un producto histórico, y sólo desde una perspectiva histórica pueden ser comprendidos [...] Es un hecho notorio que tanto la Administración actual, como el conjunto de instituciones y técnicas que integran el derecho administrativo, son en muchos casos incomprensibles si se desconocen sus raíces históricas"<sup>(1)</sup>. También señala Bello Janeiro que "cuando estudiosos actuales de otras disciplinas de derecho público deciden analizar los acercamientos puntuales de la investigación histórica correspondientes a la experiencia administrativa romana, y esforzarse en entender el lenguaje de los romanistas, en ocasiones hermético y no fácilmente comprensible para los no especialistas, o bien cuando acuden directamente a las fuentes romanas, suelen constatar la existencia de una compleja problemática administrativa en el seno de una sociedad, como la romana, en constante expansión y desarrollo"<sup>(2)</sup>.

Es evidente que el derecho romano produce en los distintos territorios bajo su dominio una marcada influencia en su estructura administrativa y en el marco jurídico que la conforma. Encontramos en este sentido distintos aspectos que hacen al derecho administrativo, a los que habré de referirme.

A. El gobierno romano dispone normas concretas respecto de la administración de "minas y canteras" (lex metallis vipascensi), recogidas más tarde por el Código Teodosiano<sup>(3)</sup>. Por lo general, se decide la centralización de la gestión de todas las zonas mineras de una región, estableciéndose la sede del procurador (procurator metallorum), que gobierna con exclusividad el distrito minero ejerciendo plena autoridad, siendo, además, representante del fisco imperial<sup>(4)</sup>.

Los "procuradores" son titulares de una verdadera oficina administrativa de gobierno, que rige todo lo concerniente a la provincia minera que se encuentra a sus órdenes, compuesta por un subprocurador (subprocurator), un secretario (commentariensis), un contable (tabularius), un cajero (arcarius), un intendente (dispensator), etc.

Esto se lleva a cabo mediante el dictado por parte del emperador de una lex dicta, que son instrucciones dirigidas a la administración de sus bienes particulares. Esto es así, por cuanto, como es sabido, el único que puede ser titular de la propiedad en Roma por el derecho quiritario es el ciudadano, por ende, los inmuebles situados en las provincias son del pueblo romano (populus romanus), de los cuales el Príncipe es administrador por constituir "dominio público" (ager publicus).

Destaco que una de las finalidades de la reforma administrativa dispuesta por Caracalla en el año 214, ordenando crear nuevas provincias (v.gr., en España), es también de carácter económico, por cuanto busca con esta medida optimizar las explotaciones auríferas de la región, dotándolas de una organización administrativa más directa para ejercer un mejor control sobre los diferentes distritos mineros. Para ello, la reforma incluye la designación de un funcionario imperial con residencia permanente en la zona, para administrar justicia y velar por la explotación económica.

También es de destacar que la búsqueda incesante de riquezas por parte del Estado romano, destinada a paliar sus necesidades de gobierno, hace que deba tomar medidas para lograrlo, como cambios de cauces de ríos, creación de embalses artificiales e innumerables acueductos.

Es interesante determinar dentro del ámbito administrativo el papel que cumple efectivamente el ejército en la compleja égida del Estado romano. De este modo, sostiene el romanista español

Rodríguez-Ennes, "los soldados desempeñaban un papel fundamentalmente técnico en las minas" y "la presencia militar debe ser puesta en relación con la política de especialización del trabajo iniciada en los yacimientos mineros a partir del siglo II, política que tiende a privilegiar los cometidos técnicos del ejército en detrimento de su misión de fuerza de seguridad"<sup>(6)</sup>, como efectuar reparaciones, organización de la red hidráulica, etc., además de la función típica de seguridad.

B. El gobierno romano tiene como norma que tras la conquista de un territorio procede a ordenarlo jurídicamente mediante el dictado de una ley específica (*lex provinciae*), por la cual determina las atribuciones del magistrado destinado a gobernarla, el *status* legal del territorio y la organización concreta de las ciudades que lo integran. Para esto, el Senado envía una comisión de diez senadores, quienes, en ejercicio del mando militar, establecen el régimen jurídico de la circunscripción provincial.

En este sentido, es necesario tener en cuenta la reforma provincial adoptada por Augusto (27 a.C.) por razones de estrategia militar, creando las provincias de Hispania Citerior, Lusitania y Bética. Luego, en el año 214, Caracalla ordena la creación de una cuarta provincia, dividiendo Sira y Britania, denominada Hispania Nova Citerior Antoniniana, manteniendo la política de los Severos con la finalidad de "evitar la concentración de poderosos efectivos militares en manos de los gobernadores provinciales". Diocleciano, a partir del año 284, decide implementar una nueva reorganización administrativa en todo el imperio, aumentando el número de provincias y agrupándolas bajo la jurisdicción de circunscripciones más amplias denominadas "diócesis"<sup>(6)</sup>, dividiendo cada una por un "vicario". A raíz de entonces, el imperio se divide en doce "diócesis" y ciento una provincias.

C. Otro aspecto interesante de la faz administrativa romana es determinar, censo mediante, el rol de las comunidades incorporadas como "unidades fiscales"<sup>(7)</sup>, es decir, saber el total por el cual la comunidad tributa, determinando número de ciudades y cantidad de población vinculada a ella<sup>(8)</sup>. En cuanto a este aspecto se refiere, destaco que las zonas mineras se encuentran "sometidas a un tipo de población estatal basado en el trabajo de las poblaciones locales dirigidas por cuadros administrativos romanos". En cuanto a esto, Rodríguez-Ennes sostiene que "este carácter estatal, no sólo de la propiedad, sino también de la explotación de los yacimientos, es el primer factor que debe tenerse en cuenta para colegir su papel en el proceso de cambio socioeconómico y de organización territorial". En cuanto a la mano de obra, mayormente local y maltratada por las autoridades de turno, en razón de que la prestación en las minas constituye "una obligación tributaria debida al Estado", es considerada jurídicamente "peregrinos *dedicticii*" (*peregrini didicticii*). En síntesis, concluye el autor citado que en las "zonas mineras" se encuentra la "conexión entre dos factores: el carácter estatal de las explotaciones y el papel de ellas en las poblaciones locales encuadradas en *civitates*". "El Estado controlaba directamente la producción y el rendimiento de las explotaciones. Ello tiene relación directa con el sistema de *civitates*, donde se encuadran las poblaciones que son utilizadas como mano de obra en la minería. Las explotaciones mineras no estaban administrativamente adscritas al territorio de la *civitas*. Se incluían en el sistema conventual como *metalla publica*, como territorios *non redditii*, y por lo tanto, pertenecientes al *ager publicus*"<sup>(9)</sup>.

También es preocupación de la administración imperial atraer al trabajo de las minas a la "mano de obra libre" (*liberi mercenarii*), ofreciendo buenas condiciones de vida y remuneración para éstos, reglamentando, asimismo, las condiciones de trabajo (v.gr., nueve horas de labor diaria para los hombres, utilización de los baños, condiciones más benévolas para las mujeres destinadas a trabajos livianos en superficie)<sup>(10)</sup>. A pesar de la existencia de diferencias locales en cuanto a la reglamentación de la "mano de obra libre", se puede generalizar un tratamiento unitario en las distintas provincias del imperio, como en Península Ibérica, Dalmacia, Mesia, Britania, África, Siria, Grecia y Galia<sup>(11)</sup>.

Esto es necesario, por cuanto la administración y explotación de las minas en sí mismas por lo general se confían a "sociedades de publicanos" (*societates publicanorum*) mediante locaciones (*locationes*). Dada su extrema importancia económica y financiera, se trata de contratistas de explotaciones públicas que los censores confieren en alquiler mediante pública subasta<sup>(12)</sup>. Como contratistas públicos, quedan sometidos a las cláusulas dictadas por los censores al adjudicar el arriendo. Estas disposiciones censorias (*leges censoriae*) establecen las condiciones de la contratación y su vinculación con el poder público<sup>(13)</sup>.

D. Una consideración diferente merecen los "municipios" (*municipium*) y las provincias.

El primero es considerado por las autoridades que ejercen el gobierno central de Roma como el núcleo urbano principal por el cual se puede arribar a determinada regularización administrativa respetando las propias formas de vida de los pueblos conquistados. En este último aspecto, es de destacar que Roma nunca tiende a aniquilar la población autóctona, salvo medidas políticas de

carácter excepcional tomadas a dicho respecto. El modo de preservarlas es otorgar pleno poder administrativo a las ciudades o municipios dentro de la jurisdicción provincial (forum). Las atribuciones municipales tratan de reunir agrupaciones de ciudadanos sometidos a normas jurídicas que originan una esfera jurisdiccional propia, pero que se encuentra sometida al poder político superior del emperador<sup>(14)</sup>.

Las provincias significan originariamente "reparto de competencia atribuida por el Senado a un magistrado"<sup>(15)</sup>. Este magistrado, gobernador, tiene la máxima jurisdicción y el derecho que aplica no es el mismo en toda la égida provincial, sino que varía según las provincias.

E. Es evidente que el derecho romano ha ejercido una influencia más que relevante en lo que se considerara el aspecto administrativo del Estado. Lo expuesto es una apretada síntesis de aquél, enfocado en aspectos puntuales como la minería, aspectos municipales, provinciales, etc., con la preocupación, incluso, de acercar las novedades que a dicho respecto se encuentra abocada la doctrina europea.

A lo analizado añado que las disposiciones tomadas por los emperadores Antoninos relativas a paliar la "niñez carenciada", el mantenimiento de los mercados en perfectas condiciones, como así también las vías públicas, acueductos, puentes, la organización de juegos públicos, los aspectos edilicios en cuanto a la elevación y preservación de edificios públicos y privados, entre otras tantas, constituyen también medidas claras de índole administrativa<sup>(16)</sup>.

Porque vale decir, como apreciación general del tema, que Roma en su esplendor es un imperio, un gobierno de naciones diversas y le es necesario tener una administración diligente. Entonces, para ello debe adoptar normas de índole administrativa. Lo contrario es el caos, y los romanos con su orden, seguridad y reglamentación cuidadosa, han demostrado precisamente lo contrario.

FRANJA  
MORADA

### CAPÍTULO XXVIII - EL DERECHO ROMANO Y EL DERECHO ANGLOSAJÓN

Se encuentra instalada en la doctrina la discusión respecto de si el derecho romano y el derecho anglosajón presentan puntos en común; si el primero origina o ha influenciado en la evolución del segundo; si se trata de sistemas distintos, etc. Los partidarios de cada postura se han dedicado a realzar las bondades y defectos respectivos. Personalmente he comenzado a investigar y a meditar el tema con mucho cuidado desde hace tiempo, inclinándome en un principio por considerar que ambos sistemas jurídicos son independientes; mas luego he reconsiderado mi posición, hasta convencerme, por el contrario, de que ambos derechos presentan diversos puntos en común, y que precisamente el derecho romano ha tenido mucho que ver en el desarrollo del derecho anglosajón. En el país mi prédica no es solitaria, por cuanto en Córdoba el romanista Juan Carlos Ghirardi ha iniciado en dicho sentido el camino hace tiempo<sup>(1)</sup>; por otra parte, en la doctrina europea tenemos, dentro de la misma tesitura, entre otros, a Peter G. Stein<sup>(2)</sup>, en Inglaterra, y a Manuel J. García Garrido<sup>(3)</sup>, en España.

Desde mi punto de vista, el derecho romano ha ejercido una considerable influencia sobre la evolución del derecho anglosajón, tanto que considero a este último como un desprendimiento menor del derecho romano clásico. La autonomía del juez y el valor del precedente en el derecho anglosajón no hacen otra cosa que recordar, más allá de diversos matices, la actividad del pretor en su apogeo durante el período republicano. Pero avancemos por partes con la idea a desarrollar. En principio, no hemos de olvidar que Inglaterra forma parte del dominio de Roma como provincia desde antiguo. Así, a fines del período republicano, Julio César arriba a sus costas vencedor de su "expedición a las Galias" (55 a.C.)<sup>(4)</sup>. Luego, Claudio (años 41 a 54) la conquista definitivamente. Más tarde, Adriano (117 a 138) erige en Escocia la famosa "muralla defensiva" que lleva su nombre (Vallum Hadriani). Su sucesor, Antonino Pío (138 a 161), finaliza la construcción de la muralla y, además, levanta diversas fortificaciones en las islas, que reafirman el poderío de Roma por espacio aproximado de cuatro siglos<sup>(5)</sup>. Por otra parte, como he dicho, la influencia de "la cultura romana" se extiende a lo largo de toda Europa, con lo que puedo afirmar que la historia de esta última no es otra cosa que la de Roma y su prolongación en el tiempo, incluso más allá de su caída definitiva como imperio en el año 1453<sup>(6)</sup>. Es evidente que Inglaterra, a pesar de su alejamiento insular, no ha quedado al margen de esto último.

En relación con ambos tipos de derecho, se dice que mientras el derecho romano es un sistema deductivo, puesto que va de lo general (ley, código, etc.) a lo particular (sentencia), el sistema anglosajón es inductivo, porque recorre el camino inverso. Esto, que al parecer es innegable, en realidad es un error de concepto, por cuanto se toma mal en consideración al derecho romano por la siguiente razón. El derecho de Roma, en lo que compete a su evolución, finaliza plasmado en la codificación moderna, de la cual es fuente de inspiración constante, pero en su inicio, o mejor dicho, en su momento histórico de mayor esplendor (período clásico), el derecho de Roma es inductivo<sup>(7)</sup>. La labor de los pretores y juristas clásicos se centra fundamentalmente en "el caso" consultado, ya sea éste real o ficticio, dicho esto último por cuanto es creado a manera de pregunta por el jurista para brindar la opinión respectiva. No trabajan de otro modo. De allí que permanentemente se habla de la "casuística" del derecho romano.

Siguiendo a Ghirardi, puedo decir que "el derecho británico presenta un dualismo entre common law y equity, similar al que el derecho romano evidencia entre derecho civil quirritario y pretorio"<sup>(8)</sup>.

Lo dicho merece detenernos un poco en ambos conceptos. El common law tiene origen con Guillermo II Plantagenet (1154-1189), quien ordena la creación de tribunales que administran "un derecho común" en toda Inglaterra. Estos tribunales reales "pronto adquirieron tan gran prestigio que desplazaron a los demás preexistentes". "La explicación era simple: aplican un derecho común en toda Inglaterra; el procedimiento, por su parte, está basado en la investigación, y finalmente el vencedor cuenta con el auxilio del poder real para ejecutar la sentencia que lo ha favorecido. Estos tribunales van a marcar, entonces, el nacimiento del common law, que se ve favorecido por dos usos forenses fundamentales empleados por ellos: los writs y el precedente"<sup>(9)</sup>.

Los writs consisten en órdenes o instrucciones dirigidas por el rey a sus tribunales para que entiendan en un caso determinado cuando un particular acude a él pidiendo justicia. La orden contiene la disposición que, de encontrarse fundado el reclamo, el tribunal tiene que hacer lugar. Si analizamos la composición del writ, advertimos que, como bien sostiene Ghirardi, "no eran otra cosa

que fórmulas, del tipo de las que la ley Aebutia había introducido en la Roma de las postrimerías de la República<sup>(10)</sup>. Y cada writ contenía, como su predecesora romana, una breve explicación del caso, siendo solamente posible una fórmula para cada tipo de litigio. Como se advierte, la actividad real era muy similar, a este respecto, a la desarrollada por los pretores de la Roma republicana<sup>(11)</sup>. En la práctica, cuando el rey concede un writ, su canciller hace lo propio en todos los casos semejantes que con posterioridad se fuesen presentando, con lo que logra lentamente que todos los casos sean absorbidos por los tribunales reales. Las sentencias son registradas en un libro denominado Anuario (Year Book), que si bien no tienen carácter de fuerza obligatoria para casos futuros, tienen mucha utilidad, por cuanto los abogados ven favorecida su actividad en la exposición del caso ante el juez, indicándole que un determinado principio ha sido aplicado con anterioridad en un caso similar. De este modo, y al decir de Ghirardi, "se consagró la popularmente llamada 'ley de los casos juzgados' (stare decisis), obviamente no escrita, pero no por ello menos respetada. La sentencia, norma individual dictada en un caso concreto, se hace precedente, que es obligatorio para los jueces que ulteriormente deban resolver cuestiones similares"<sup>(12)</sup>. El precedente tiene gran valor en el derecho anglosajón y Ghirardi, en su exhaustiva investigación, señala al respecto que "tradicionalmente se ha sostenido que los precedentes judiciales, cuya acumulación conforma ese cuerpo normativo que conocemos como el common law, son relevantes en tanto y en cuanto sacan a la luz la costumbre preexistente. Desde ese punto de vista, el common law estaría constituido por las costumbres prolongadas e inmemoriales tal cual han sido declaradas por los jueces en sentencias precedentes". También enseña que "contra esta teoría tradicional ha reaccionado la moderna doctrina, conforme a la cual el precedente no se limitaría a sacar a la luz un derecho preexistente, sino que, yendo mucho más allá, lo crearía. Su función sería, no meramente declarativa, sino constitutiva"<sup>(13)</sup>.

Más arriba he dicho que el derecho anglosajón descansa en el common law y la equity. De manera sucinta me he referido al primero, restando ahora hablar de la segunda. La equity es un "cuerpo de normas jurídicas y precedentes, paralelas a las del common law, que procuraban hacer justicia en situaciones no alcanzadas por éste"<sup>(14)</sup>. Tiene su origen en el nacimiento de tribunales judiciales que se originan como desprendimientos de aquellos primitivos creados por Guillermo II. Estos nuevos tribunales ("Corte de Chancery") "dieron origen a un nuevo cuerpo de normas jurídicas y precedentes. Dicho nuevo cuerpo recibió el nombre de equity"<sup>(15)</sup>.

En síntesis, ambos sistemas coexisten hasta que inevitablemente se contraponen. Así, primero, en el siglo XVII, ante un conflicto de aplicación se resuelve que el common law es el derecho que tiene que aplicarse, y solamente debe acudir a la equity para los casos en que el primero no puede resolver. Luego, en el año 1813, se decide unificar ambos sistemas, estableciendo que en caso de conflicto entre ambos deben prevalecer los principios de la equity<sup>(16)</sup>.

Otro aspecto que hace a la cuestión, y no debe dejarse de lado en el presente análisis, es la creación en Inglaterra de la denominada "Corte del Almirantazgo" (Court of Admiralty) bajo el reinado de Eduardo III, abocada al "derecho marítimo". Esto último en función del incremento del poderío inglés en los mares. El "Tribunal del Almirantazgo" utiliza "un procedimiento basado prioritariamente en el derecho romano, en donde no tenían cabida el sistema de la investigación y los jurados del common law"<sup>(17)</sup>. Entiende sobre seguros y contratos marítimos, fletes y casos de piratería y tiene jurisdicción sobre la tripulación de los barcos ingleses y sobre los delitos cometidos en alta mar por cualquier súbdito británico. Señala Ghirardi que "la independencia del derecho marítimo frente al común se mantuvo, no siendo jamás absorbido por éste. Y si bien el Tribunal del Almirantazgo dejó de subsistir independientemente, cuando las leyes de 1873 y 1875 reorganizaron el sistema judicial inglés, desde entonces se estableció la Admiralty Division como una de las secciones de la High Court of Justice, para entender en las cuestiones de derecho marítimo"<sup>(18)</sup>.

A lo expuesto debo agregar lo concerniente a la enseñanza del derecho en Inglaterra, en donde, adelantando mi opinión, se advierte la gran influencia del derecho romano. En efecto, este último es enseñado en un principio por Vacario, exponente de la Escuela de Bolonia, llevado a Inglaterra por el arzobispo Teobaldo de Canterbury alrededor del año 1140. Al parecer, Vacario enseña en las Escuelas de derecho de Lincoln y Oxford, y para facilitar la tarea de los estudiantes "compiló una colección de textos esenciales extraídos del Digesto y el Código. Esta compilación se encontraba dividida en nueve libros y se la conoció como "libro de los pobres" (liber pauperum). Más tarde, este texto es utilizado en Oxford, donde se enseña el derecho civil a la par del derecho canónico. Los discípulos de Vacario se mantienen en contacto con los avances de la "Escuela de Bolonia"<sup>(19)</sup>.

Alrededor del año 1230, el "derecho común inglés" es recogido por el Tratado latino sobre las leyes y costumbres de Inglaterra, conocido como Bracton. Éste, según señala Stein, "aunque basado en los repertorios de los tribunales regios, utilizó, y en algunos casos adoptó, las categorías del derecho civil romano derivados de la Summa codicis de Azzo. El autor del Bracton entendió que si el derecho de los tribunales regios iba a ser presentado como un conjunto coherente, se



necesitaría una estructura de nociones generales que tan sólo se encontraba articulada en el derecho romano"<sup>(20)</sup>. Y continúa diciendo Stein que "muchos pasajes recuerdan al lenguaje del Digesto y del Código, no tanto por la cita formal como por el uso de frases procedentes de los textos romanos que el mismo autor había deslizado en su exposición"<sup>(21)</sup>. Concluye Stein diciendo al respecto que estos indicios demuestran que en el autor del Bracton "el derecho romano se había incorporado a su modo de pensar como jurista. Su tratado dotó al naciente derecho común de la estructura teórica mínima necesaria para desarrollarse de manera coherente"<sup>(22)</sup>.

Destaca Stein que Eduardo I, rey de Inglaterra y de parte de Francia durante los años 1272 y 1307, "se interesó mucho por los problemas del gobierno y del derecho", y para "estas tareas reclutó a su servicio a Francis Accursio, hijo del gran glosador y jurista, él mismo de gran reputación por méritos propios"<sup>(23)</sup>. Por su parte, señala García Garrido que "el cultivo del derecho romano fue favorecido por Enrique VIII en el siglo XVI"<sup>(24)</sup>. Para esta época también es de destacar la actividad del bartolista italiano Alberto Gentili, que se encuentra radicado en Inglaterra, autor de una obra de derecho internacional llamada *De legationibus*, que trata de la diplomacia en Roma y especialmente el "derecho romano y las relaciones internacionales". Gentili tiene en cuenta los textos del *Corpus Iuris*, distinguiendo especialmente el derecho civil y el derecho natural y de las naciones. Este autor comienza el proceso de creación del derecho internacional como disciplina distinta del derecho civil, completando, más tarde, Grocio este proceso<sup>(25)</sup>.

En el siglo XVIII, lord Mansfield recomienda como "la mejor introducción al derecho romano para un caballero en Harvard College la obra *Notae*, de Vinio, "dirigida exclusivamente a estudiantes, en la que buscaba explicar las Instituciones conforme a las mejores ideas humanistas, si bien con pequeñas referencias a la práctica"<sup>(26)</sup>.

Es después, en el siglo XIX, que "comenzó en Inglaterra una educación jurídica parecida a lo que continentalmente se entiende por ésta", correspondiendo a John Austin, discípulo de Jeremy Bentham, "la teoría general del derecho", para lo cual toma los conceptos jurídicos de los romanistas alemanes. Austin tiene en cuenta "el tratado de Savigny sobre la posesión" y el "sistema de derecho de Pandectas", de Thibaut, señalando que "ir del estudio del derecho inglés al estudio del derecho romano, es escapar del imperio del caos y la oscuridad a un mundo que parece por comparación la región del orden y la luz"<sup>(27)</sup>.

Por su parte, en la misma época también habrá de añadirse la labor de Henry Sumner Maine, en Cambridge, en favor de la importancia del derecho romano, sosteniendo que éste "proporciona un conjunto de categorías e infunde un modo especial de razonar".

Finalmente, y en cuanto a la influencia del derecho romano en Inglaterra, debo destacar la conclusión a que arriba García Garrido cuando señala que "la jurisprudencia romana y su técnica casuística es punto de partida y base para el estudio y conocimiento, tanto del derecho europeo de los Códigos Civiles, como del sistema judicial angloamericano, constituyendo el punto de referencia imprescindible para el proceso de creación y adaptación del derecho a las necesidades de nuestra época"<sup>(28)</sup>.

En igual sentido, Stein atinadamente señala que "la idea de que el derecho de la Unión Europea no es en algún sentido una cosa nueva, sino más bien una reanudación de una unidad cultural y jurídica, que una vez existió en todo el continente, ha encendido el interés por lo que es descrito como 'la tradición civil'. Este interés traza el desarrollo de las doctrinas jurídicas desde el derecho de Justiniano hasta los códigos modernos y hace públicas las contribuciones de los estudiosos de diferentes países sobre dicha cuestión. El resultado de tales estudios ha puesto de relieve el alcance con el cual los conceptos jurídicos elaborados por los romanos han sobrevivido en forma reconocible a todos los cambios impuestos sobre ellos por parte de aquellos que trataban de adaptarlos a las necesidades actuales"<sup>(29)</sup>.

En suma, concluyo esta apretada síntesis respecto del "derecho romano y el anglosajón" aportando mi parecer en cuanto a lo que señalé al iniciar el tema acerca de que "el derecho anglosajón es un desprendimiento mejorado del sistema romano clásico". En efecto, si tomamos en cuenta las razones geográficas que hacen que Inglaterra, más allá de su alejamiento insular histórico, forme parte del imperio romano y se encuentre inserta en el mundo y cultura occidentales y que desde antiguo enriquece sus escuelas de derecho con juristas del continente, es evidente que la influencia del derecho romano se hace intensa en el anglosajón. La semejanza de los writs y la equity con "las acciones del procedimiento formulario" no debe ser interpretada de otro modo. El derecho clásico romano basa su fundamento en "el caso", tal como después lo hace el derecho anglosajón, que, más allá de diferentes matices, mantiene en ristre el estudio de la realidad aportada por éste. El derecho anglosajón continúa trabajando mediante "el sistema inductivo" aportado por el valor del precedente, mientras el derecho romano, siguiendo con su propia madurez evolutiva, se

despoja de este sistema para pasar al "deductivo". El sistema anglosajón persiste en el "sistema inductivo", el valor de los writs y la equity, y el "precedente" como creador del derecho, continuando con el viejo y siempre generoso sistema procesal romano clásico ("derecho de acciones"), por cuanto es el que mejor se adapta a su propia realidad histórica. Por su parte, el "derecho romano", que es madre conceptualmente de todo el derecho europeo, prosigue su camino en pos de la necesaria e inevitable codificación. Por cierto, en mi opinión, no se puede ser tajante en el tema y señalar que ambos sistemas son absolutamente independientes. He sostenido más arriba la gran influencia que tiene el derecho romano sobre el derecho anglosajón. Y justamente es en el período que los autores consultados señalan como el más oscuro históricamente para Inglaterra como aquel que su sistema judicial comienza a diferenciarse del romano.

FRANJA  
MORADA

## Bibliografía General

### BIBLIOGRAFÍA GENERAL

- ALBA CRESPO, J. J., Acciones e interdictos populares, Eudecor, Córdoba, 1999.
- ÁLVAREZ CORREA, E., Curso de derecho romano, Bogotá, 1979.
- ÁLVAREZ SUÁREZ, U., Instituciones de derecho romano, Artigrafía, Madrid, 1973.
- ARANGIO RUIZ, V., Historia de derecho romano, Reus, Madrid, 1943.
- Instituciones de derecho romano, Depalma, Buenos Aires, 1986.
- ARGÜELLO, L. R., Continúa la transfusión del derecho romano en la Argentina, Editorial Tucumán, 1985.
- Manual de derecho romano, Astrea, Buenos Aires, 1988.
- ARIAS RAMOS, J., Derecho romano, Revista Derecho Privado, Madrid, 1960.
- ASTOLFI, R., La lex Iulia et Papia, Cedam, Padova, 1970.
- AULO GELIO, Noches Áticas, EJEa, Buenos Aires, 1959.
- BARRY, N., Introducción al derecho romano, Civitas, Madrid, 1987.
- BELLAVITIS, M., Diritto processuale civile, Cedam, Padova, 1935.
- BIALOSTOSKY, S., Panorama del derecho romano, Unam, México, 1982.
- BIONDI, B., Istituzioni di Diritto Romano, Giuffrè, Milano, 1946.
- BLOCH, R., Los etruscos, Eudeba, Buenos Aires, 1993.
- BONFANTE, P., Historia de Roma, Revista Derecho Privado, Madrid, 1944.
- BONFANTE, P., Instituciones de derecho romano, Madrid, 1965.
- BURDESE, A., Manual de derecho público romano, Bosch, Barcelona, 1972.
- CAMINOS, S. A., Sentencias de Paulo, UNT, Tucumán, 1994.
- CARAMÉS FERRO, J. M., Instituciones de derecho privado romano, Perrot, Buenos Aires, 1963.
- Curso de derecho romano, Perrot, Buenos Aires, 1971.
- CARCOPIÑO, J., Las etapas del imperialismo romano, Paidós, Buenos Aires, 1968.
- La vida cotidiana en Roma en el apogeo del Imperio, Hachette, Buenos Aires, 1944.
- CATALANO, P., Diritto e Persone, Torino, 1990.
- Constitución Deo Auctore y Libro I del Digesto, Lima, 1990.
- CAYO JULIO CÉSAR, Comentarios a la Guerra Civil, Alianza, Madrid, 1985.
- Comentarios de la Guerra de las Galias y de la Guerra Civil, Sarpe, España, 1985.
- CAYO CORNELIO TÁCITO, Anales del Imperio Romano, Sarpe, Madrid, 1985.
- CAYO CRISPIO SALUSTIO, La Guerra de Yugurta. La conjuración de Catalina, Sarpe, Madrid, 1985.
- CAYO SUETONIO, Los Doce Césares, Sarpe, Madrid, 1985.
- CERMEÑO TAPIA, G., Manus y matrimonio, Mérida, 1988.
- CHAPOT, V., El mundo romano, Cervantes, Barcelona, 1928.
- Códigos Antiguos de España, Madrid, 1885.
- CORNELL, T. - MATTHEWS, J., Roma. Legado de un imperio, Folio, Madrid, 1993.

CORRENTE SPANÓ, D. D., Fuentes del derecho romano, Peannedille, Buenos Aires, 1970.

Código Teodosiano, traducción, Díaz Biale, A. - Vázquez, H. - Pautaso, S. A. - Cooper, R. P. A, Córdoba, 1966.

Corpus Iuris Civilis, Fraetres Kriegelii, Stuttgart, 1887.

Corpus Iuris Civilis, traducción, García del Corral, I., Madrid, 1887.

COSTA, J. C., Temas de derecho romano, Buenos Aires, 1994.

— El derecho de familia y de las personas en Roma, Estudio, Buenos Aires, 1997.

— El negocio jurídico en Roma. Influencia en el derecho argentino, Estudio, Buenos Aires, 1998.

— El Alto Imperio o Principado, Estudio, Buenos Aires, 2001.

— Derecho sucesorio romano, Estudio, Buenos Aires, 2002.

— La ley de las XII Tablas. La primera ley escrita. De la Monarquía República, Estudio, 2002.

CUENCA, H., Proceso civil romano, EJE, Buenos Aires, 1957.

DE FRANCISCI, P., Síntesis histórica del derecho romano, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1954.

DE MARTINO, F., Storia della costituzioni romana, Nápoles, 1990.

DÍAZ BIALET, A., El derecho romano en la obra de Vélez Sarsfield, unc, Córdoba, 1952.

— La recepción del derecho romano en la Argentina, Alveroni, Córdoba, 2000.

DI PIETRO, A., Gaius, Institutas, Librería Jurídica, La Plata, 1975.

— Verbum Iuris, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1968.

— Derecho privado romano, Depalma, Buenos Aires, 1996.

— Los negocios jurídicos patrimoniales y los contratos en el derecho romano, Ábaco, Buenos Aires, 2004.

DI PIETRO A. - LAPIEZA ELLI, A. E., Manual de derecho romano, Buenos Aires, 1994.

D'ORS PÉREZ PEIX, A., Presupuestos críticos para el estudio del derecho romano, US, Salamanca, 1943.

— Derecho privado romano, un, Pamplona, 1989.

ELGUERA, E. R. - RUSSOMANO, M. C., Curso de derechos reales en el derecho romano, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1972.

ESPINÓS, J. - MACÍ, P. - SÁNCHEZ, D. - VILAR, M., Come vivevano i romani, Fenice, Milán, 2000.

EUGENIO, F., Breve historia de Roma, Dykinson, Madrid, 1991.

FERRERO, G., Grandeza y decadencia de Roma, Jorro, Madrid, 1908.

FOSS, C. - MAGDALINO, P., Roma y Bizancio, Folio, Barcelona, 1996.

FUSTEL DE COULANGES, N. D., La ciudad antigua, Selene, Buenos Aires, 1985.

GALLEGOS GARCÍA, M., Estudios de derecho romano, Comahue, 1996.

GARCÍA GARRIDO, M. J., Derecho privado romano, Dykinson, Madrid, 1980.

GARNEY, P. - SALLER, R., El Imperio Romano. Economía, sociedad y cultura, Crítica, Barcelona, 1990.

GAROFALO, L., Il processo edilizio, Cedam, Padova, 1989.

— Sulla condizione di 'homo sacer' in età arcaica, Roma, 1990.

— Il Pretore giudice criminale in età repubblicana? In margine ad una risposta, Roma, 1991.

— Studi sull'Azione Redhibitoria, Cedam, Padova, 2000.

GAVERNET, H. R. - MOJER, M. A., El romano. La tierra. Las armas, La Plata, 1992.

GHIRARDI, J. C., El derecho romano y el derecho anglosajón, Explanatio, Córdoba, 1994.

— Temas doctrinarios. Casos de la stirpe de los Publio Venator, La Ley, Buenos Aires, 2005.

GHIRARDI, Juan C. - ALBA CRESPO, Juan J., Derecho romano, Eudecor, Córdoba, 1993.

GLOVER, T. R., El mundo antiguo, Eudeba, Buenos Aires, 1983.

GLUCK, F., Comentario alle pandette, Milán, 1889.

GRANT, M., Storia di Roma Antica, Newton Compton, Roma, 1990.

GIBBON, E., Historia de la decadencia y ruina del Imperio romano, Hispamérica, Madrid, 1995.

GRIMAL, P., El siglo de Augusto, Eudeba, Buenos Aires, 1965.

— La formación del Imperio Romano, Eudeba, Buenos Aires, 1986.

— Virgilio o el segundo nacimiento de Roma, Eudeba, Buenos Aires, 1987.

HEINECCIO, J. G., Historia del derecho romano, Sanz y Sanz, Madrid, 1845.

— Recitaciones del derecho civil según el orden de la Instituta, Salvá, París, 1847.

HERODIANO, Historia del Imperio Romano después de Marco Aurelio, Gredos, Madrid, 1985.

HOMO, L., La Italia primitiva y los comienzos del imperialismo romano, Uteha, México, 1960.

— La Civilisation Romaine, Payot, París, 1930.

HORACIO, F. Q., Odas, Doménech, Barcelona, 1882.

IGLESIAS, J., Derecho romano. Instituciones de derecho privado, Barcelona, 1972.

JOSEFO, Claudio, Autografía contra Apión, Alianza, Madrid, 1987.

JUSTINIANO, El Digesto. Libro I, Lima, 1990.

JUVENAL, Sátiras, Madrid, 1973.

KOVALIOV, S. I., Historia de Roma, Sarpe, Madrid, 1986.

KUNKEL, Historia del derecho romano, Barcelona, 1981.

LANCON, B., La vita cotidiana nel Tardo Imperio, Milán, 1999

LAPIEZA ELLI, A., Historia del derecho romano, Cooperativa de Derecho, Buenos Aires, 1948.

LEVI, A., Historia de la filosofía romana, Eudeba, 1980.

LOUZÁN DESOLIMANO, N. D., Curso de historia e instituciones del derecho romano, Lumiere, Buenos Aires, 2001.

LOUZÁN DE SOLIMANO, N. D. - COSTA, J. C. - ROSENFELD, L. C., y otros autores, El procedimiento civil romano. Su vigencia en el derecho argentino, Belgrano, Buenos Aires, 1993.

LOZANO CORBI, E., La legitimación popular en el proceso romano clásico, Bosch, 1982.

— Sinopsis de historia e instituciones de derecho romano, Mira, Zaragoza, 1994.

MARCO AURELIO, Meditaciones, Planeta, Madrid, 1994.

MARCO TULIO CICERÓN, Obras completas. Vida y discursos, Anaconda, Buenos Aires, 1946.

MAYNZ, C., Curso de derecho romano, Barcelona, 1887.

MEHESZ ZOLTAN CORNEL, El pretor y la jurisprudencia pretoriana, unc, Córdoba, 1967.

MEIRA, S., Teixeira de Freitas o juriconsulto de Imperio, Olimpo, Brasília, 1983.

MILLAR, F., El Imperio Romano y sus pueblos limítrofes, Siglo XXI, México, 1994.

MOJER, M. A., La ley de las XII Tablas, Unlp, La Plata, 1994.

MOMMSEM, T., Compendio del derecho público romano, Madrid, 1893.

— Historia de Roma, Hachette, Buenos Aires, 1953.

— Derecho penal romano, Temis, Bogotá, 1966.

— El mundo de los Césares, FCE, México, 1982.

MONTANELLI, I., Historia de Roma, Plaza & Janés, Barcelona, 2001.

MORINEAU INDÚRATE, M. - IGLESIAS GONZÁLEZ, R., Derecho romano, Unam, México, 1987.



ORTOLAN, M., Explicación histórica de las instituciones del emperador Justiniano, Madrid, 1887.

— Instituciones de Justiniano, Buenos Aires, 1964.

PEÑA GUZMÁN, L. A. - ARGÜELLO, L. R., Derecho romano, Tea, Buenos Aires, 1962.

PETIT, E., Tratado elemental de derecho romano, Albatros, Buenos Aires, 1975.

PIGANIOL, A., Historia de Roma, Eudeba, Buenos Aires, 1981.

PLAUTO, Obras completas, Anaconda, Buenos Aires, 1947

PONSSA DE LA VEGA DEMIGUENS, N., Reglas de Ulpiano, Lerner, Buenos Aires, 1970.

— Manual de historia del derecho romano, Lerner, Buenos Aires, 1984.

RABINOVICH-BERKMAN, R. D., Derecho romano, Astrea, Buenos Aires, 2001.

RASCÓN GARCÍA, C., Manual de derecho romano, Tecnos, Madrid, 1992.

REICH, J., La Italia prerromana, Folio, Madrid, 1995.

REMONDON, R., La crisis del Imperio Romano. De Marco Aurelio a Anastasio, Labor, Barcelona, 1979.

RICCOBONO, S., Roma, madre de las leyes, Depalma, Buenos Aires, 1975.

RODRÍGUEZ DE FONSECA, B. A., El Digesto del emperador Justiniano, traducción, Madrid, 1872.

ROLDÁN, J. M., El imperialismo romano. Roma y la conquista del mundo mediterráneo, Síntesis, Madrid, 1994.

RONGA, G., Corso di istituzione di diritto romano, Ute, Torino, 1899.

ROSTOVITZEF, M., Roma. De los orígenes a la última crisis, Eudeba, Buenos Aires, 1993.

RUSSOMANO, M. C., La posesión en el derecho romano, Esnaola, 1964.

— Curso de instituciones de derecho romano, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1970.

— Breve historia del derecho romano, Buenos Aires, 1988.

SAMPER, F., Derecho romano, euv, Santiago de Chile, 1975.

SANTALUCIA, B., Y Libri Opinione Di Ulpiano, Giuffrè, Milán, 1971.

SAVIGNY, M. F. C., Sistema del derecho romano actual, Buenos Aires, 1954.

SCHIPANI, S., Las fuentes romanas citadas por D. Vélez Sarsfield en las notas del Código Civil de la República Argentina, Lima, 1966.

SCIALOJA, V., Procedimiento civil romano, Buenos Aires, 1954.

SÉNECA, De la brevedad de la vida y otros tratados, Madrid, 1965.

— De la cólera, Madrid, 1986.

SIMÓN, M., Los primeros cristianos, Eudeba, Buenos Aires, 1993.

STEIN, P. G., El derecho romano en la historia de Europa, Siglo XXI, Madrid, 2000.

TALAMANCA, M., Istituzioni di diritto romano, Giuffrè, Milano, 1990.

TEIXEIRAS DE FREITAS, A., "Código Civil Proyecto", Revista Nacional, Buenos Aires, 1900.

TITO LIVIO, Décadas de la historia de Roma, Sep, México, 1987.

TORRENT, A., Manual de derecho privado romano, Mira, Zaragoza, 1990.

VÁZQUEZ, H., Derecho romano de ayer y de siempre, Jano, Córdoba, 1986.

— Diccionario de derecho romano, Zavallía, Buenos Aires, 1998.

— Temas de derecho romano, Advocatus, Córdoba, 1993.

VÁZQUEZ, H. y otros autores, Acerca de los diversos modos de citar el Corpus Iuris Civilis, Córdoba 1992.

— El derecho romano en la biblioteca del Dr. Vélez Sarsfield, unc, Córdoba, 1996.

— La tacha de infamia en Roma, UNC, Córdoba, 1995.

VILLEY, M., El derecho romano, Eudeba, Buenos Aires, 1963.

VIRGILIO, Bucólicas. Geórgicas, Alianza, Madrid, 1983.

VON IHERING, R., El espíritu del derecho romano en las diversas fases de desarrollo, Madrid, 1989.

# FRANJA MORADA